

- 378 -
Trescientos
setenta
y ocho.



EXPEDIENTE N° 016-2024
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRO ÚNICO: HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
DEMANDANTE: CONSORCIO HUACARMAYO
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

EXPEDIENTE N° 016-2024

CONSORCIO HUACARMAYO
(Demandante)

vs.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR
(Demandado)

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Arbitro Único
Abog. Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza

Secretaria Arbitral
Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur

Huánuco, 05 de mayo del 2025

377
Trescientos
setenta
y siete

RESOLUCIÓN ARBITRAL N°04-2025/HITS/HCO

Huánuco, 05 de mayo del 2025

VISTOS: El expediente Arbitral; en la ciudad de Huánuco, en la presente fecha, el Tribunal Arbitral, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la LCE, RLCE, la LEY DE ARBITRAJE y las normas establecidas por las PARTES, valorado las pruebas ofrecidas y actuadas en este arbitraje, revisando los argumentos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda, contestación de demanda, con respeto riguroso del debido proceso y la igualdad de las partes, dicta el presente Laudo Arbitral de Derecho.

DATOS GENERALES Y ABREVIATURAS

1.1. DATOS GENERALES:

Demandante	: CONSORCIO HUACARMAYO
Demandada	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR
Contrato	: Contrato N°004-2023-MDH/GM
Servicio	: Contratación del servicio de limpieza y descolmatación del río huacarmayo en la localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia Ambo, departamento de Huánuco.
Proceso de Selección	: Adjudicación simplificada
Monto del contrato	: S/ 734,706.67 (Setecientos treinta y cuatro mil setecientos seis con 67/100 soles)
Fecha de la convocatoria	: 14 de noviembre de 2023
Fecha de firma del contrato	: 11 de diciembre de 2023
Inicio del arbitraje	: 17 de septiembre de 2024
Tipo de arbitraje	: Institucional, Nacional y de Derecho


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tahur
SECRETARÍA ARBITRAL

- 376 -
Trescientos
setenta y
seis

- Resolución del contrato
- Condena de costas y costos arbitrales.

1.2. ABREVIATURAS:

ACTA DE INSTALACIÓN : Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único de fecha 19 de diciembre del 2024.

COD : Cuaderno de Obra Digital.

EL CENTRO : Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

EL CONTRATO : Contrato N° 004-2023-MDH/GM de fecha 11 de diciembre del 2023, suscrito para la contratación del servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

EL CONTRATISTA : Consorcio Huacarmayo

EL DEMANDANTE

EL CONSORCIO

(indistintamente)

EL SERVICIO

: Contrato N° 004-2023-MDH/GM de fecha 11 de diciembre del 2023, suscrito para la contratación del servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

LA ENTIDAD

LA DEMANDADA

LA MUNICIPALIDAD

(indistintamente)

: Municipalidad distrital de Huácar

LAS PARTES

: Conjuntamente el demandante y demandado

LCE

: Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada con Decreto Legislativo N° 1444.


Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO ÚNICO


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL

LEY DE ARBITRAJE

: Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.

LPAG

: Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

OSCE

: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

**PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN**

: Adjudicación Simplificada DU 032 N° 01-2023-MDH/CS- Primera Convocatoria para la contratación del servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

REGLAMENTO

: Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

RLCE

: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo N° 167-2023-EF.

RLPAG

: Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

TUO de la LPAG

: Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

2.1. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE

Según lo dispuesto en el ACTA DE INSTALACIÓN, las PARTES establecieron como sede del arbitraje la ciudad de Huánuco y como sede institucional del arbitraje el local del CENTRO ubicado en el jirón 28 de Julio N° 1167, 2do piso, oficina 05, de esta localidad de Huánuco Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco. Sin perjuicio de ello, las actuaciones arbitrales podrán realizarse fuera de esta sede, o de manera remota a través de la plataforma virtual (correo:

imperium.sg.2021@gmail.com). Todas las decisiones, resoluciones y comunicaciones del Árbitro Único se entienden emitidas en la sede del arbitraje, sin perjuicio del lugar físico donde se encuentren sus miembros o del lugar donde sean firmados los instrumentos que las contienen.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Parte Demandante:

Razón Social : CONSORCIO HUACARMAYO
RUC : 20611894890
Representante : Kethny Justino Malpartida Pino
DNI : 74122830
Abogado : Nami Florida Ponce
Domicilio legal : CPM Jancao Mz. B lote 9, distritos de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco
Correo electrónico: consorciohuacar28@gmail.com y namifp1@hotmail.com

Parte Demandada:

Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR
RUC : 20189021764
Representante : Gerente Municipal Gilde Carbajal Valladares
DNI : 23015964
Abogado : Emerson Víctor Bacilio Ingunza
Domicilio (s) : Jr. Grau N°502, distrito de Huácar, provincia de Ambo, departamento de Huánuco.
Domicilio (s) : Jr. Dámaso Beraún N° 817, segundo piso oficina 03, distrito, provincia y departamento de Huánuco.
Correo : municipalidaddistritalhucar@gmail.com y basilioingunzaemerson@gmail.com

2.3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Producto del Contrato N° 004-2023-MDH-GM de fecha 11 de diciembre del 2023, suscrito para la contratación del servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUÁCAR", correspondiente a la Adjudicación Simplificada DU 032 N° 01-2023-MDH/CS- Primera Convocatoria, celebrado entre el CONSORCIO y la MUNICIPALIDAD.

2.4. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL:

El presente arbitraje se inicia en amparo del convenio arbitral contenido en la Cláusula décima octava del Contrato N° 004-2023-MDH-GM de fecha 11 de diciembre del 2023, que dice:

“... Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado...”

2.5. COMPETENCIA ARBITRAL:

Conforme indica la Cláusula décima octava del Contrato N°004-2023-MDH-GM de fecha 11 de diciembre del 2023 y estando al acuerdo de las PARTES, se estableció la competencia del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional “Corporación Imperium” y su reglamento para conocer la presente causa, por lo que en aplicación del artículo 11° del D.L. 1071, atendiendo también a lo indicado por el numeral 225.1, 225.4 del artículo 225° e inciso b) numeral 226.2 del artículo 226° del RLCE, así como por el Principio de Autonomía de la Voluntad o Voluntariedad, las partes han tomado la decisión de sustraerse del sistema de justicia tradicional para someter la solución de sus conflictos a la justicia arbitral, con plena libertad para elegir a los árbitros, reglas del proceso, lugar y ley aplicable de ser el caso.

2.6. TIPO DE ARBITRAJE:

El arbitraje es Institucional, Nacional y de Derecho conforme a lo dispuesto por el Convenio Arbitral, la LCE y el RLCE.

2.7. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

De conformidad con lo establecido por los artículos 23 y 26 del REGLAMENTO, las PARTES dejaron a consideración de la Directora del CENTRO a fin de designar al Árbitro Único que conocería la presente controversia; siendo nombrada como Árbitro Único al abogado Teodomiro Pelayo Beteta Venturo, quien luego de su designación, declaración de Independencia, Imparcialidad, disponibilidad y

comunicando de manera formal su aceptación al cargo, mediante el ACTA DE INSTALACIÓN se fijaron las reglas definitivas del proceso arbitral y se declaró que el Tribunal Arbitral en calidad de Arbitro Único se encontraba válidamente constituido. Además, la designación del Árbitro Único se efectuó de acuerdo con las reglas establecidas por las PARTES y el REGLAMENTO, quienes manifestaron su conformidad con el procedimiento de designación, no habiéndose planteado objeción o recusación alguna durante el proceso arbitral.

MARCO LEGAL APLICABLE AL ARBITRAJE:

- 2.8.1. De acuerdo con lo señalado en el ACTA DE INSTALACIÓN, la Ley aplicable al fondo de la controversia en el presente proceso será la Ley peruana.
- 2.8.2. Sin perjuicio de lo señalado, resulta conveniente precisar que, con respecto a las normas procesales aplicables al presente arbitraje, será de aplicación el REGLAMENTO y la LEY DE ARBITRAJE.
- 2.8.3. En cuanto al fondo de la controversia, ésta se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes a la fecha de convocatoria del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, tal como menciona el OSCE a través de la Opinión N° 033-2022/DTN que dice:

“... Al respecto, debe mencionarse que la Constitución, en su artículo 103, señala que “(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley (...)”.

Además, debe agregarse que el artículo 109 de la Constitución dispone: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.

A partir de las mencionadas disposiciones se entiende que, en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento rige la denominada teoría de los hechos cumplidos, es decir que la ley es obligatoria desde su entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial, y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

Sobre el particular, es importante señalar que el numeral 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional derivada del Expediente N° 0002-2006-PI/TC dice que “Diez – Picaso, (...) sostiene que en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad (...)”.

En ese sentido, como regla general la ley se aplica a los hechos y situaciones que surjan desde que entra en vigencia y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes lo que incluye a aquellas, surgidas bajo la legislación anterior y que aun produzcan efectos, salvo que la misma ley establezca algún tipo de excepción...” (Énfasis agregado)

Ello en concordancia con lo señalado por la Opinión N° 057-2019-DTN, en el cual se establece:

“Conforme a lo indicado al absolver las consultas anteriores, la Ley permite que el contrato –derivado de un proceso de contratación– se rija conforme a la normativa que correspondía a dicho proceso, que para la materia en consulta se refiere a la normativa vigente al momento de su convocatoria.

Asimismo, durante la ejecución contractual pueden presentarse una serie de controversias, como, por ejemplo, las referidas a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, las cuales se resolvían mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, tal como lo dispone el artículo 52 de la anterior Ley. Así, antes de la culminación del contrato y dentro del plazo fijado en el anterior Reglamento, las partes podían iniciar algunos de los medios de solución de controversias antes citados, entre ellos el arbitraje.

En tal sentido, a efectos de solucionar las controversias producidas durante la ejecución del contrato, debían aplicarse las disposiciones previstas en dicho documento contractual, el mismo que se perfeccionó en el marco de la normativa vigente al momento de la convocatoria del correspondiente proceso de selección, sin perjuicio de aquellas disposiciones procedimentales que en el marco de un arbitraje iniciado resulten aplicables al desarrollo del mismo.” (Énfasis agregado)

2.8.4. Consecuentemente, la ley aplicable al fondo de la controversia es la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” modificada con Decreto

Legislativo N° 1444 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo N° 167-2023-EF; de igual manera, también se aplicará la jurisprudencia en la materia emitida por el OSCE.

- 2.8.5. A su vez, y estando a lo dispuesto en la cláusula DECIMO SÉPTIMA del CONTRATO, solo en lo no previsto en este contrato, la LCE y el RLCE, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

2.9. DEL EJERCICIO LEGÍTIMO DEL DERECHO DE DEFENSA DE LAS PARTES:

- 2.9.1. El demandante presentó su Demanda Arbitral dentro del plazo otorgado. La demandada fue debidamente emplazada con dicha demanda, la misma que fue contestada.
- 2.9.2. Las partes, durante el proceso arbitral, ofrecieron medios probatorios que fueron incorporados por la Árbitro Único para tener mayores elementos para resolver, así como se tiene medios probatorios de oficio requeridos por el Árbitro único.
- 2.9.3. Las partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideraran pertinentes, sin limitación alguna, así como para expresar sus posiciones de hecho y de derecho, habiendo tenido amplia oportunidad de presentar sus alegatos escritos y de informar oralmente, con la participación de sus abogados, respetando en todo momento su irrestricto ejercicio del derecho de defensa, en igualdad de condiciones, en resguardo del debido proceso.

2.10. SOBRE LOS GASTOS ARBITRALES:

- 2.10.1. Mediante las reglas fijadas por las PARTES en el ACTA DE INSTALACIÓN, se estableció el costo total del presente proceso arbitral, en la suma de S/15,500.00 (QUINCE MIL QUINIENTOSCON 00/100 SOLES), la misma que debía ser cancelada en forma equitativa por las partes, a razón de S/ 7,7500.00 (SIETE MIL SETESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100) por cada una, no estando incluido en este monto lo establecido en el segundo párrafo del numeral 22 de la referida Acta, ni los costos que irroguen de producirse medios probatorios de oficio, indicados en el numeral 33 de la misma.

2.10.2. Asimismo, se estableció que en caso que una de las partes asumiera el pago de los honorarios y gastos administrativos, ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que la Árbitro se pronuncie al momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.

2.10.3. Sin perjuicio de ello, se estableció que la Árbitro Único puede establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje.

2.10.4. Así también, se debe dejar constancia que la totalidad de los Costos Arbitrales fueron asumidos únicamente por la DEMANDANTE.

2.11. DEL LAUDO:

2.11.1. El presente laudo es emitido dentro del plazo establecido. Se considera necesario resaltar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, así como producir certeza en el juzgador (arbitro) respecto a las pretensiones planteadas, de acuerdo a lo consagrado por los principios generales en materia probatoria.

2.11.2. De igual forma, la Árbitro Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y si de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que esto genere algún tipo de nulidad.

2.11.3. Asimismo, se advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

2.11.4. Finalmente, la Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en su laudo todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas.


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARIA ARBITRAL

2.11.5. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.

PLAZO PARA LAUDAR:

Tal como se estableció en el ACTA DE INSTALACIÓN, el Tribunal Arbitral dicta el presente el Laudo Arbitral dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del cierre de las actuaciones y a lo dispuesto mediante Resolución Arbitral N° 03-2025/AU/HITS/HCO de fecha 21 de abril del 2025.

PRINCIPALES ANTECEDENTES PROCESALES:

- 3.1. Con fecha 17 de septiembre del 2024, el DEMANDANTE presenta al CENTRO la solicitud de arbitraje.
- 3.2. Con fecha 01 de octubre del 2024, se emite la Resolución Directoral N° 38-2024/D(e)GLET/HCO mediante la que se admite a trámite la solicitud de arbitraje y se corre traslado a la DEMANDADA, quien fuera válidamente notificada en su domicilio legal con fecha 03 de octubre del 2024.
- 3.3. Con fecha 25 de noviembre de 2024, la DEMANDADA se apersona al proceso, designa abogado defensor y señala sus domicilios a efectos de las notificaciones procesales.
- 3.4. Con fecha 25 de noviembre del 2024, se lleva a cabo el Acta de Registro Sobre los Actos de Preparación de la Audiencia Especial con la asistencia de ambas PARTES, en la cual se establece la forma de comunicación durante la tramitación del proceso arbitral y acuerdan que sea el CENTRO, mediante su directora, quien designe al árbitro único que conocerá el proceso, con todo lo demás que contiene.
- 3.5. Con fecha 03 de diciembre del 2024, se emite la Resolución Directoral N°49-2024/D(e)GLET/HCO mediante la cual, entre otros, se considera la propuesta de la directora encargada del CENTRO sobre la designación de la Abg. Heidi Ivonne Torres Santos para que ocupe el cargo de Arbitro Único, se le pone de conocimiento a dicha profesional para su aceptación, se señala fecha para la audiencia de instalación del tribunal arbitral y demás trámites correspondientes.
- 3.6. Con fecha 19 de diciembre del 2024, se emite el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único mediante la cual se fijan las reglas del proceso

arbitral, se designa al Abg Heidi Ivonne Torres Santos como Arbitro Único y se declara por válidamente instalado el Tribunal Arbitral, entre otros.

3.7. Con fecha 16 de enero de 2025, el DEMANDANTE presenta su demanda arbitral, adjuntando sus respectivos medios probatorios.

3.8. Con fecha 21 de enero de 2025, se emite la Resolución Arbitral N° 01-2024/AU/HITS/HCO mediante se admite a trámite la demanda arbitral, y se corre traslado con los anexos correspondientes a la parte demandada, a fin de que conteste.

3.9. Con fecha 31 de enero del 2025 el DEMANDADO, a través de su Abogado Emerson Víctor Basilio Ingunza, cumple con absolver la demanda arbitral.

3.10. Con Resolución Arbitral N° 02-2024/AU/HITS/HCO 19 de febrero de 2025 se señala Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.

3.11. Con fecha 17 de marzo el demandante presenta su propuesta de puntos controvertidos.

3.12. Con fecha 19 de marzo se lleva a cabo Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, donde se otorga a las partes el plazo de 05 (CINCO) días para presentar sus alegatos finales.

3.13. Con fecha 27 de marzo de 2025, el Consorcio Huácar presenta su escrito bajo la sumilla: Presento Alegatos.

3.14. Con Resolución Arbitral N° 03-2025/AU/HITS/HCO su fecha 21 de abril de 2025 se señala fecha para emisión de Laudo arbitral el mismo que ha sido válidamente notificado con fecha 21 de abril de 2025 a las partes procedimentales.

4. PUNTOS CONTROVERTIDOS:

- ✓ **PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único DECLARE LA NULIDAD y/o INEFICACIA de la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM, de fecha 14 de agosto de 2024, a través de la Carta Notarial N° 008-2024-MDH-GM, que declara RESOLVER en forma total el Contrato N° 004-2023-MDH/GM, de fecha 11 de diciembre de 2023, del servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

✓ **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que, el Árbitro Único ORDENE a la Municipalidad Distrital de Huácar mantenga los efectos jurídicos en el caso de la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM, de fecha 14 de agosto de 2024, ORDENE a la Municipalidad Distrital de Huácar mantenga y/o restablezca el STATU QUO del Contrato N° 004-2023-MDH/GM, suscrita el 11 de diciembre de 2023, entre Consorcio Huacarmayo y la Municipalidad Distrital de Huácar. Asimismo, determinar si corresponde o no que el árbitro ORDENE la formalización de la recepción del servicio "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no que, el Árbitro Único, condene a una o a las dos partes el pago de la totalidad de costas y costos irrogados en el presente proceso arbitraje.

MEDIOS PROBATORIOS:

Medios probatorios de la DEMANDA

1. Contrato Privado de "CONSORCIO HUACARMAYO"
2. Contrato N°04-2023-MDH-A, de fecha 11 de diciembre de 2023
3. Acta de Entrega de Terreno.
4. Acta de Inicio de Ejecución de Servicio
5. CARTA N° 04-2023 CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/R, de fecha 18 de diciembre de 2023, informe de compatibilidad del expediente técnico y el terreno
6. CARTA N° 05-2023 CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL, documento con la cual se presenta el Adicional N° 01 - Deductivo N° 01, con fecha del 19 de diciembre del 2023.
7. CARTA N° 004-2023-WPRP/S, de fecha de 20 de diciembre 2023, documento de la supervisión, Evaluación y aprobación de Expediente Adicional N° 01-Deductivo N° 01.
8. RESOLUCIÓN N° 302-2023-MDH/GM, que aprueba el adicional N° 01-Deductivo N° 01.
9. CARTA N° 06-2023 CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL, documento con la cual se presenta la valorización Contractual.
10. CARTA N° 07-2023 CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL, documento con la cual se presenta la valorización del Adicional N° 01 - Deductivo 01.
11. Acta de recepción de Servicio, con observaciones, con fecha de 26 de enero de 2024.

12. CARTA N° 001-2024-WPRP/S, de fecha de 04 de enero de 2024, se solicita la nueva fecha de recepción y conformidad del servicio.
13. N°003-2024-WPRP/S, se hace de conocimiento la culminación del servicio con lo que se solicita la conformación del servicio.
14. CARTA N° 01-2024-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL, de fecha 07 de marzo de 2024, descargo a la municipalidad.
15. CARTA N° 02-2024-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL, de fecha de 22 de abril de 2024, se reitera la solicitud de recepción y conformidad de servicio.
16. CARTA N° 03-2024-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL, de fecha 10 de mayo de 2024, respuesta a la CARTA NOTARIAL N° 001-2024-MDH/GM de fecha 07 de mayo de 2024
17. Asientos del Cuaderno de Obra (desde el asiento 01 al asiento 31)
18. Panel fotográfico, a través de las tomas fotográficas, al término del servicio "Limpieza y Descolmatación del Río Huacarmayo en la localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco"
19. Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM, de fecha 14 de agosto de 2024, notificada a través de la Carta Notarial N° 008-2024-MDH-GM, que declara RESOLVER en forma total el Contrato N° 004-2023-MDH/GM, de fecha 11 de diciembre de 2023, del servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

Medios probatorios de la CONTESTACIÓN.

Ofrece los mismos medios probatorios de la demanda.

6. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único DECLARE LA NULIDAD y/o INEFICACIA de la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM, de fecha 14 de agosto de 2024, a través de la Carta Notarial N° 008-2024-MDH-GM, que declara RESOLVER en forma total el Contrato N° 004-2023-MDH/GM, de fecha 11 de diciembre de 2023, del servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".

Posición del DEMANDANTE

6.1 La DEMANDANTE señala:

-364-
Trescientos
sesenta
y cuatro

1.- Que, con fecha 28 de noviembre de 2023 se adjudica la BUENA PRO, y con fecha 01 de diciembre de 2023 se dio por consentida la Buena Pro del Proceso de Selección AS-DU-032-2023-SM-01-2023-MDH/CS-1, para la contratación del Servicio: "Limpieza y Descolmatación del Río Huacarmayo, en la Localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco".

2.- Que, con fecha 11 de diciembre de del 2023, se suscribe el Contrato N° 004-2023-MDHI/GM, entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR y el CONSORCIO HUACARMAYO, para la contratación del servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO", por el monto ascendente a S/. 734,706.67 (Setecientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Seis con 67/100 Soles), incluido los impuestos de Ley;

3.- Que, con fecha 12 de diciembre de 2023, se realizó el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO DEL SERVICIO "Limpieza y Descolmatación del Río Huacarmayo, en la Localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco" al contratista para la ejecución del servicio, conjuntamente con los representantes de la municipalidad y la supervisión. Siendo así, con fecha 13 de diciembre de 2023, se da INICIO DEL SERVICIO "Limpieza y Descolmatación del Río Huacarmayo, en la Localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco",

4.- Que con CARTA N° 04-2023 CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL, de fecha 18 de diciembre de 2023, se presenta a la supervisión el informe de compatibilidad del expediente técnico del servicio "Limpieza y Descolmatación del Río Huacarmayo, en la Localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco".

5.- Que con CARTA N° 003-2023-WPRP/5, de fecha 19 de diciembre de 2023 el Ing. Williams Paul Rodríguez Palacios Supervisor del Servicio, presenta a la Municipalidad Distrital de Huácar la Ratificación de la necesidad de ejecutar el Adicional – Deductivo del SERVICIO: "Limpieza y Descolmatación del río Huacarmayo, en la Localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco".

6.- Que con CARTA N° 05-2023 CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL, de fecha 20 de diciembre de 2023, mi representada presenta a la supervisión el Expediente Técnico de Adicional N° 01 – Deductivo N° 01 para el Servicio "Limpieza y Descolmatación del río Huacarmayo, en la Localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco. El mismo que es aprobada a través de la Resolución N° 302-202-MDH/GM, de fecha del 22 de diciembre del 2023,

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
GABRIELA LUREJO ENRIQUETA TORRES
SECRETARÍA GENERAL

HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA
ARBITRO ÚNICO

-363-
Trescientos
sesenta
y tres

7.- En esa medida, con fecha del 26 de diciembre de 2023, se culmina el servicio de "Limpieza y Descolmatación del Río Huacarmayo, en la Localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco, por lo que se presenta la valorización N°01, del contractual mediante Carta N° 06-2023-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL, ante la supervisión, tal como se indica en el cuaderno de ocurrencias asiento N° 27, solicitando la recepción del servicio materia del presente contrato.

8.- Con fecha del 26 de diciembre de 2023 se termina el servicio "Limpieza y Descolmatación del Río Huacarmayo, en la Localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco" del Adicional N°01 – Deductivo N°01, por lo que se presenta la valorización N°01 del Adicional N°01 – Deductivo N° 01 con la Carta N° 07-2023-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL, a la supervisión. Adjuntando las copias del cuaderno de obra en la que se informa la culminación del servicio y se solicita la recepción del servicio. la misma que consta en el cuaderno de ocurrencias asiento N° 27.

9.- Que mediante Carta N° 001-2024-WPRP/S, de fecha 04 de enero de 2024, la supervisión informo a la Entidad la culminación y solicito la conformación del comité para recepción de servicio.

10.- Con fecha del 17 de enero del 2024, la entidad se realiza el pago por el servicio, la misma que efectúa una retención del 10% por el concepto de la retención por fiel cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el contrato N° 004-2023-MDH/GM Clausula séptima: Garantías.

11.- Con fecha del 26 de enero del 2024, se suscribe el Acta de Recepción de Servicio, con observaciones, en la cual se nos otorga un plazo de 6 días calendarios para el levantamiento de observaciones.

12.- Que, con fecha del 01 de febrero del 2024, mediante asiento N° 30 del cuaderno de ocurrencias se señala la terminación del levantamiento de observaciones, solicitándose a la supervisión su trámite correspondiente; en ese sentido la supervisión mediante Carta N° 003-2024-WPRP/S, informa a la entidad la culminación del levantamiento de observaciones y solicitando la nueva fecha de recepción del servicio.

13.- Con fecha del 05 de febrero del 2024, presenta la supervisión la Carta N° 004-2024-WPRP/S, con los planos de replanteo final del servicio.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echevarría Tassir
SECRETARÍA ARBITRAL

- 362 -
Trescientos
sesenta
y dos

14.- Con CARTA N° 005-2024-WPRP/S, de fecha 23 de febrero de 2024, se presentó la subsanación del levantamiento de observaciones y la solicitud de nueva recepción del servicio "Limpieza y Descolmatación del Río Huacarmayo, en la Localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco",

15.- Que, mi representada con Carta N° 01-2024-CONSORCIO HUACARMAYO/KIMP/RL, de fecha 07 de marzo de 2024, responde al Oficio N° 193-2024-MDH-OCI, en mérito al INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 002-2024-OCI/0398-SVC. La misma que fue remitida con Carta N° 123-2024-MDH/GM, por la Municipalidad Distrital de Huácar, periodo 05 de febrero de 2024 al 13 de febrero de 2024, en el cual indica dos situaciones adversas en la ejecución del Servicio de Limpieza y Descolmatación del Río Huacarmayo en la Localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo- Departamento Ambo", siendo así, se detalla:

A). SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR ORTORGARON CONFORMIDAD PARA PAGO DE VALORIZACIONES DEL CONTRATISTA PESE A NO HABER REALIZADO LA RECEPCION DEL SERVICIO; SITUACION QUE GENERA EL RIESGO QUE LA ENTIDAD HAYA EFECTUADO PAGO CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES;

Ante ello, se efectuó el descargo correspondiente, la misma que se encuentra conforme lo señalado en las bases en su numeral 3.8 PAGOS: "El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato", (el subrayado es nuestro); es así, que de la sección específica - condiciones especiales del procedimiento establece en su numeral 2.5 FORMA DE PAGO, señala "La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales, de acuerdo al avance registrado en cada periodo del mes (...) debiendo contar con la siguiente documentación: - informe del contratista de los trabajos ejecutados durante el mes, (...); - concordante con el numeral 11 de la misma;

La misma que se encuentra establecido en la Clausula Cuarta del contrato: del Pago, La entidad se obliga a pagar en contraprestación a el contratista en soles en pagos parciales (...).

Que, ante la situación adversa invocada, resulta necesario indicar, que los pagos efectuados por la entidad para la valorización N° 01, tiene fundamento legal, que conforme con lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 138 del Reglamento, indica que "El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes".

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

SECRETARÍA ARBITRAL
Gabriela Lucero Echevarría Taji

-361-
Trescientos
sesenta
y uno

Conforme lo señala Rubio Correa, "la norma imperativa es aquella que debe ser necesariamente cumplida por los sujetos, sin que exista la posibilidad lógico-jurídica contrario. Por el contrario, la norma supletoria es aquella que sólo se aplica cuando no hay otra que regule el asunto; o la que se aplica a las relaciones privadas cuando las partes no han hecho declaración de voluntad expresa sobre el asunto (...)"¹. Adicionalmente el autor señala, "la variable que distingue entre normas imperativas y supletorias no es "su obligatoriedad o no obligatoriedad", ni siquiera "la fuerza obligatoria" sino, su vocación normativa: la norma quiere disponer sin admitir voluntad contraria, o sólo quiere suplir la ausencia de otra norma". (Opinión N° 008-2021/DTN.)

En esa medida, quedo desvirtuada el informe de contraloría de que los funcionarios debieron de haber recepcionado el servicio previo a la cancelación del pago a cuenta 01,

B).- MUNICIPALIDAD DE HUACAR NO CONTO CON AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, GENERA EL RIESGO DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

Al respecto, en aplicación del art. 142 del RLCE, la Entidad es la responsable de dicha autorización, la misma que se encuentra registrado en la Autoridad Nacional del Agua – SIGRD, el cual no es obligación contractual;

En ese sentido, estando al informe de contraloría se puede advertir que el servicio fue ejecutado conforme a las bases integradas, no se ha transgredido norma alguna o incumplido obligaciones contractuales;

Por tanto, cabe resaltar que se ha cumplido a cabalidad el procedimiento de solicitar la recepción del servicio. Asimismo, resulta necesaria aclarar que al término de las labores se solicita la RECEPCIÓN DEL SERVICIO para lo cual el procedimiento que origina es trámite es DAR LA CONFORMIDAD por intermedio de la Supervisión a raíz de la culminación de los trabajos. Consecuentemente, conforme lo establecido en las bases, en el contrato, este trámite de RECEPCIÓN DEL SERVICIO es independiente de las formas de Pago.

En esa medida, mi representada presento la Carta N° 06-2023-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL y Carta N°07-2023-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL, de fecha 26 de diciembre del 2023, por el cual se remite a la Supervisión la Valorización del Servicio y del Adicional N° 01, respectivamente. Lo cual se elaboró en base a la culminación de los trabajos solicitados en el Servicio y en el Adicional N°01 y Deductivo vinculante N°01, lo que ha sido ratificado en el Asiento N° 28 del Supervisor.

16.- Que, a través de la Carta N° 02-2024-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL de fecha del 22 de abril de 2024, mi representada reitera la solicitud de recepción del servicio y conformidad del servicio.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echivarria Talur
SECRETARÍA ARBITRAL

360 -
Trescientos
sesenta

17.- Que, a través de la CARTA NOTARIAL N°001-2024-MDH-GM, de fecha 07 de mayo de 2024, la Municipalidad Distrital de Huácar, solicita cumplir sus obligaciones contractuales, la misma que fue absuelto mediante Carta N°003-2024-CONSORCIO HUACARMAYO/KIMP/RL de fecha del 10 de mayo de 2024, sustentando haber cumplido con el Servicio: "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, DEÁRTMAENTO DE HUANUCO". Solicitando se emita la RECEPCIÓN DEL SERVICIO, debido que mi representada ha cumplido con sus obligaciones contractuales para con la entidad;

18.- Sin embargo, mediante Carta Notarial N° 008-2024-MDH-GM, de fecha 19 de agosto de 2024, remite la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM, de fecha 14 de agosto de 2024, a través de la cual la Entidad declara RESOLVER en forma total el Contrato N° 004-2023-MDH/GM, de fecha 11 de diciembre de 202, del servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO";

19.- Que, el artículo 1351° del Código Civil, en relación al contrato señala "El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial". Asimismo, el artículo 1402° del mismo cuerpo normativo señala "El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar extinguir obligaciones"

La doctrina se ha pronunciado respecto del contrato señalando que: "Se puede definir como un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos, o más, personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. Es el contrato, en suma, un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones relativos."

Valpuesta Fernández señala que: "el contrato es el instrumento que confiere el ordenamiento jurídico a los particulares para que, en ejercicio de la autonomía de su voluntad privada y mediante la concordancia entre dos o más voluntades, regulen sus derechos creando, regulando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas patrimoniales, es lógico que produzca sus efectos entre los otorgantes. Es decir, la eficacia del contrato, en cuanto creador de normas jurídicas entre particulares (privados), queda limitada a las partes que han intervenido en su celebración y los herederos de éstas por ser quienes las suceden en todos sus derechos y obligaciones; los terceros no se pueden perjudicar ni beneficiar con un contrato en el cual no son parte."

Que, el Artículo 1352 del Código Civil, indica "Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad". Y en su Artículo 1359, establece "No hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria";

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL

Las normas citadas, hacen referencia al principio de consensualidad, que es entendido como: "el resultado del consenso entre las partes respecto a las formas y condiciones de un negocio, de un acuerdo o compromiso. Como es obvio, sólo existe consenso cuando todas las partes integrantes de un negocio aceptan, expresan su voluntad respecto a las condiciones pactadas en él.

En aplicación al principio de especialidad, la Ley de Contrataciones del Estado establece la obligación de incorporar en el texto del contrato, una cláusula específica sobre la posibilidad de resolver el contrato suscrita entre las partes. Así, numeral 32.1 del artículo 32, establece "El contrato debe celebrarse por escrito y de ajusta a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la entidad durante el mismo" [...]. Así también en cuanto al procedimiento de resolución de contrato propiamente dicho, el artículo 165 del RLCE

20.- De la recurrida se tiene sustento al Informe N° 383-2024-MDH/UOLSEC-GIDUR/DGCA, de fecha 26 de abril de 2024, que la ejecución del servicio "Limpieza, descolmatación del Río Huacarmayo en la localidad de Huácar, Provincia de Ambo Departamento de Huánuco":

A) Se ha llevado a cabo sin advertencia, deficiencia y/o defecto del expediente técnico debido a que la entidad desconoce hasta el momento cualquier comunicado del profesional para gastos de control y cierre de la actividad de limpieza o autorización alguna por mejoras a la prestación del presente servicio.

Es pertinente señalar que la entidad es la única responsable de la elaboración del expediente técnico correspondiente. En ese contexto, mi representada, a través de la Carta N° 04-2023 CONSORCIO HUACARMAYO/KIMP/RL, de fecha 18 de diciembre del 2023 en el marco de la presentación del informe de compatibilidad advierte las deficiencias presentadas en dicho expediente técnico. Estas deficiencias fueron que motivaron, posteriormente, el Adicional N° 01 – Deductivo N°01.

Adicionalmente, el Informe señala que, conforme a la topografía, se evidencia ciertas incongruencias de las secciones del río tal como se indican en el expediente técnico. Esta situación fue también detallada en Asiento N°03 del residente de obra de fecha del 14 de diciembre del 2023;

Resulta necesario señalar que, a través del cuaderno de Ocurrencias (mencionado previamente), se ratifica la incompatibilidad de las secciones del río que indica el expediente técnico.

De igual manera, en la Carta N° 003-2023-WPRP/S, emitida por el supervisor con fecha 19 de diciembre del 2023, se confirma la RATIFICACIÓN DE ANOTACIÓN DE CUADERNO OBRA SOBRE LA NECESIDAD DE EJECUTAR ADICIONAL-DEDUCTIVO, en dicho documento, el Supervisor, tras realizar la evaluación pertinente, confirma que los planos de las secciones transversales (ST-1 y ST-2) y el replanteo de campo presentan variaciones en el ancho del río, lo que respalda la solicitud de ajustes.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echevarría Taffur
SECRETARÍA ARBITRAL

ARBITRO ÚNICO

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza

En esa medida, mediante CARTA N° 05-2023 CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL, de fecha 19 de diciembre del 2023, se presenta el expediente técnico correspondiente al Adicional N°01 – Deductivo N°01, en el cual se sustentó en un levantamiento topográfico que permitió justificar las secciones reales del río y evidenciar los volúmenes totales contemplados en el proyecto original.

Así mismo, en respuesta a lo anterior, el Supervisor emitió la Carta N° 004-2023-WPRP/S, de fecha del 20 de diciembre del 2023, mediante la "EVALUACION Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE ADICIONAL N°01-DEDUCTIVO N°01" en este documento tanto mi representada como la Supervisión fundamentaron la incompatibilidad topográfica, señalando la necesidad de modificar el tramo a intervenir para la realizar los trabajos de descolmatación. Estas modificaciones fueron debidamente sustentadas en el levantamiento topográfico y en la aprobación de los planos para el Adicional N°01 – Deductivo N° 01.

Cabe señalar que la premura del plazo del Servicio contratado implicaba tomar acciones rápidas, dado que la temporada de avenidas comienza en el mes de diciembre. Esta urgencia queda reflejada en las imágenes presentadas en la valorización correspondiente al mes de diciembre.

Durante la ejecución, se identificaron incompatibilidades topográficas en el expediente técnico original. Esto generó la necesidad de un Adicional N° 01 - Deductivo N° 01, aprobado el 22 de diciembre de 2023, con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°302-2023-MDH/GM, de fecha 22 de diciembre del 2023;

Ahora bien, se presentó dos Valorizaciones:

La Valorización N° 01, con un avance de 53.85 % del Contractual

La Valorización del Adicional N° 01 – Deductivo N° 01, con un avance de 46.15 %.

El total de ambas asciende al 100 %, lo cual refleja la ejecución total de los trabajos conforme al expediente técnico aprobado.

El consorcio cumplió con los trabajos contratados y los adicionales requeridos, tal como lo avala la supervisión en diversas comunicaciones.

La supervisión confirmó que las metas establecidas (longitud de descolmatación y volúmenes de materiales) fueron alcanzadas.

En esa línea, mediante el Cuaderno de Ocurrencias, en el asiento N° 28 de la Supervisión, con fecha 26 de diciembre de 2023, se da conformidad a los metrados del expediente contractual y a los metrados del expediente adicional N° 01 – Deductivo N° 01. En dicho asiento, la Supervisión también comunica a la entidad la verificación de la ejecución de las partidas al 100 % y solicita la conformación del comité de recepción para proceder con los trámites correspondientes. El mismo que mediante Carta N° 001-2024-WPRP/S, de fecha 04 de enero de 2024, la Supervisión informa sobre la culminación del servicio y solicita la conformación y la conformación del comité para la recepción del servicio.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabiela Lucero Echivarria Tafur
SECRETARIA ARBITRAL

B) Que, el profesional para gastos y control de cierre de la actividad de limpieza no solicito ni comunico de manera formal la culminación del servicio a la entidad, como también el contratista, de lo contrario habría presentado fuera del plazo de recepción del servicio (23/04/24), ya que como fecha máxima se tenía al 05 de enero de 2024 y por ende se evidencia que supera el 10% de máxima penalidad, ya que habría llegado a acumular el máximo de penalidades.

Al respecto, conforme se advierte en el cuaderno de ocurrencias en asiento N° 27 del Responsable Técnico, de fecha 26 de diciembre de 2023, en la que se indica la ejecución de las partidas al 100 %, así mismo la supervisión a través del cuaderno de correncias asiento N° 28 de la Supervisión, de fecha 26 de diciembre de 2023, LA SUPERVISIÓN DA LA CONFORMIDAD A LOS METRADOS DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y LOS METRADOS DEL EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01 – DEDUCTIVO N° 01 y comunica a la entidad la verificación de la ejecución de las partidas al 100 %, solicitando a la entidad la conformación del comité de recepción y proceda con la recepción, también la supervisión presenta la Carta N° 001-2024-WPRP/S, de fecha 04 de enero de 2024, la supervisión informo a la Entidad la culminación y solicito la conformación del comité para recepción de servicio. Siendo así, con fecha del 26 de enero del 2024, se suscribe el Acta de Recepción de Servicio, con observaciones, en la cual se nos otorga un plazo de 6 días calendarios para el levantamiento de observaciones.

En esa medida, con fecha del 01 de febrero del 2024, mediante asiento N° 30 del cuaderno de ocurrencias se señala la terminación del levantamiento de observaciones, solicitándose a la supervisión su trámite correspondiente; por lo que, la supervisión mediante Carta N° 003-2024-WPRP/S con fecha de 05 de febrero de 2024, informa a la entidad la culminación del levantamiento de observaciones y solicitando la nueva fecha de recepción del servicio. Consecuentemente, a través de la Carta N° 004-2024-WPRP/S, de fecha 05 de febrero del 2024, la supervisión presenta los planos de replanteo final del servicio.

Que, con CARTA N° 005-2024-WPRP/S, de fecha 23 de febrero de 2024, la supervisión reitera la comunicación de la subsanación del levantamiento de observaciones y la solicitud de nueva recepción del servicio "Limpieza y Descolmatación del Río Huacarmayo, en la Localidad de Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco". Por el mismo mi representada reitera a través de la Carta N° 02-2024-CONSORCIO HUACARMAYO/KIMP/RI de fecha del 22 de abril de 2024, la solicitud de recepción del servicio.

En este extremo, podemos advertir que la recurrida falta a la verdad, al presumir que mi representada habría presentado fuera del plazo la recepción del servicio (23/04/24), cuando conforme obra en anexos, se ha cumplido con el procedimiento. Los trabajos principales y adicionales culminaron el 26 de diciembre de 2023, respaldados por el cuaderno de ocurrencias, cartas de la supervisión y actas correspondientes. Cuya recepción preliminar: El 26 de enero de 2024, se emitió un acta de recepción con observaciones, que fueron levantadas el 1 de febrero de 2024, conforme consta en el cuaderno de ocurrencias;

C). - Que, la Municipalidad Distrital de Huácar, en su resolución del citado Contrato, argumenta que el contratista no ha cumplido con las metas establecidas en el expediente técnico.

Según dicho expediente, se indicaba una longitud de 826.00 metros lineales de descolmatación en el Río Huacarmayo; a esta cifra se suman los 1,210 ml del expediente adicional N° 01 – Deductivo N° 01, lo que da un total de 2,036 ml de descolmatación. Este volumen de descolmatación de cauce de río es 24,386.00 m³, conformación de talud con material propio es 22,806.13 m³ y la eliminación de material excedente 4,566.45 m³, los mismos se puede corroborar mediante los planos de replanteo presentados a la entidad, el panel fotográfico y el Acta de Constatación Física realizada el 16 de octubre de 2024, en la que se verifica la ejecución de 2,120.00 ml de descolmatación.

La demandada argumentó que el contratista no cumplió con las metas técnicas, sin embargo, mi representada demuestra que:

- Los avances técnicos fueron verificados y aprobados por la supervisión.
- Las observaciones fueron levantadas dentro del plazo estipulado.
- No existió retraso atribuible al contratista.

20.- También, es importante señalar que la CARTA NOTARIAL N° 001-2024-MDH-GM, emitida el 07 de mayo de 2024, carece de congruencia y motivación. La Gerencia Municipal notificó al Consorcio, solicitando cumplir con sus obligaciones contractuales en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de resolución de contrato. Fundamentando que, en mérito a las acciones por adoptar de parte de la Entidad señalado en el Informe N° 0951-2024-MDH/GIUDR, de fecha 26 de abril de 2024, del Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, en el 5.3 la ejecución de servicio "limpieza, descolmatación del río Huacarmayo en la localidad de Huácar, Provincia de Ambo Departamento de Huánuco", se ha llevado a cabo sin advertencia, deficiencia y/o defecto del expediente técnico debido a que la entidad desconoce hasta el momento cualquier comunicado del profesional para gastos de control y cierre de la actividad de limpieza o autorización alguna por mejoras a la prestación del presente servicio, 5,4 (...)

Al respecto, mi representado objeto en todos sus extremos los comentarios que han generado y que anteceden a la citada Carta Notarial, rechazando su resolución de contrato.

21.- En mérito a lo expuesto precedentemente se colige que a pesar de que el contratista cumplió con todos los procedimientos en su ejecución y recepción; la entidad contratante, actuó de manera arbitraria e ilegal, que sin motivación alguna resolvió en forma total el Contrato N° 004-2023-MDH/GM, de fecha 11 de diciembre de 2023, sobre el servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO", a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM, de fecha 14 de agosto de 2024, notificada con Carta Notarial N° 008-2024-MDH-GM. Cuya resolución unilateral, no tomó en cuenta las evidencias presentadas por el contratista ni las verificaciones de la supervisión, se basó en argumentos insuficientes y contradijo los informes de avance. Consecuentemente la recurrida deviene en nula, por lo que solicita, se declare fundada la primera pretensión principal.

Posición de la DEMANDADA

6.2 Por su parte, la DEMANDADA señala:

Que, habiendo sido notificado válidamente el 23 de enero del presente año 2024 con cédula de notificación arbitral N° 006, la Resolución Arbitral N° 001-2025/AU/HITS/HCO de fecha 21 de enero de año 2025, en la que resuelve admitir a trámite la demanda interpuesta por el CONSORCIO HUACARMAYO, y estando dentro del plazo acordado en el Acta de Instalación del tribunal Arbitral y conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional, es que recorro a su despacho a efectos de contestar la solicitud de arbitraje, en base a las pretensiones de la demanda, en los términos siguientes:

Que, correspondiente a la primera pretensión, se declare **INFUNDADA** la demanda, ya que la Municipalidad Distrital de Huácar, conforme a ley, emitió una Resolución Gerencial Municipal N° 267-2024-MDH/GM de fecha 14 de agosto del año 2024, en la cual **RESUELVE EN FORMA TOTAL EL CONTRATO NOTARIAL N° 004-2023-MDH/GM** de fecha once de diciembre del año dos mil veintitrés, realizado con la empresa contratista CONSORCIO HUACARMAYO, del servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", por cuanto se ha resuelto dicho contrato de acuerdo a las normas legales, y las causales para la nulidad correspondiente; por lo cual queda desacreditado lo mencionado por la empresa.

I FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO.- Que, con fecha 11 de diciembre del año 2023, la Municipalidad distrital de Huacar, celebró un Contrato N° 004-2023-MDH/GM, con la empresa CONSORCIO HUACARMAYO, para la ejecución del servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", con un plazo de sesenta y cuatro días calendarios.

SEGUNDO.- Que, con fecha 13 de diciembre del año dos mil veintitrés, se da inicio a la prestación de servicio y que con fecha catorce de diciembre del año dos mil veinticuatro se culmina el plazo de prestación de servicio: "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".

TERCERO.- Que, el contratista CONSORCIO HUACARMAYO, presenta la valorización N° 01, correspondiente al mes de diciembre al profesional de gastos de control de cierre de la actividad de limpieza, y valorización, quien mediante Carta N° 006-2023-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL y Carta N° 007-2023-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL dejando claro que no evaluó, ni revisó el procedimiento correcto y a la conformidad de servicio, y que todo pago se realiza al consorcio solamente a lo ejecutado y no se le puede pagar por algo que no ha hecho, poniendo a conocimiento a que no se ha cumplido en su totalidad, y que por tal motivo se emite la Gerencia Municipal la Resolución N° 267-2024-MDH/GM.

359
Trescientos
cincuenta y
cuatro.

CUARTO.- Que, el contratista CONSORCIO HUACARMAYO, se ve en la causal para resolver el contrato debido a que éste no cumplió con presentar la recepción formal del servicio dentro del plazo legal, conforme lo estipula el numeral 165.4 del artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, donde señala claramente que "la entidad puede resolver el contrato, sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos solamente basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato, acto realizado por la entidad municipal, en la cual se emitió mencionada Resolución Administrativa, conforme a los lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y otros.

QUINTO.- Que, con fecha 14 de agosto del año 2024, la Municipalidad Distrital de Huácar, emite una Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM, en la cual en forma total **RESUELVE EN FORMA TOTAL EL CONTRATO N° 004-2023-MDH/GM** de fecha once de diciembre del año dos mil veintitrés, realizado con la empresa contratista CONSORCIO HUACARMAYO, del servicio de "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", EN LA LOCALIDAD DE HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", por motivos de incumplimiento injustificado a la ejecución de sus obligaciones contractuales a su cargo, ya que no cumplió descolmatar de manera completa todo el río, es por ello a que se emite la presente resolución anteriormente mencionada.

SEXTO.- Que, con fecha 19 de agosto del año 2024 se emitió Carta Notarial N° 08-2024-MDH-GM, en la cual mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM, se le comunico la Resolución del Contrato, y de acuerdo al plazo ya no es procedente por cuanto ya ha prescrito su derecho para la interposición de la presente demanda, la solicitud de la reconsideración administrativa establecido y que la misma se le ha notificado la Resolución del contrato mediante con fecha 03 de setiembre del 2024,

SEPTIMO.- Que, se califique debidamente todas las documentaciones presentadas por el demandante conforme corresponda, ya que la Municipalidad Distrital de Huácar, actuó dentro de la legalidad y respeto a los principios que rigen las contrataciones, y resuelva de acuerdo a la pretensión se haya sometida al mismo arbitraje.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

Consideraciones Previas: Sobre la obligatoriedad de la LCE y su Reglamento

- 6.3 Previamente debemos tener en cuenta que según el Anexo N° 01 -Definiciones del RLCE, el contrato es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación

jurídica dentro de los alcances de la Ley y de dicho Reglamento; además, según el artículo 138° de dicho cuerpo normativo, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, el contrato incluye, bajo responsabilidad, cláusulas referidas a: i) Garantías, ii) Anticorrupción, iii) Solución de controversias y iv) Resolución por incumplimiento; además, tratándose de los contratos de obra se incluyen, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual.

- 6.4 Por su parte, la propia LCE reconoce la preponderancia y obligatoriedad de su contenido, incluyendo sus procedimientos y plazos, sobre cualquier otra norma, señalando en su Primera Disposición Complementaria Final que:

“... La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas...” (Énfasis agregado)

- 6.5 Dicho carácter obligatorio también ha sido reconocido por el RLCE, que en su Artículo 2° señala:

“... Artículo 2. Competencias en materia de contrataciones del Estado

2.1. Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el Reglamento son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación.

2.2. Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lo dispuesto en el numeral anterior...” (Énfasis agregado)

- 6.6 Por lo tanto, corresponde a las partes que intervienen en una contratación pública, tal como la MUNICIPALIDAD y el CONSORCIO, el respeto irrestricto a los procedimientos y demás instituciones establecidas por la LCE y el RLCE, como el que corresponde a la Ampliación de Plazo, Penalidades, Resolución de Contrato, etc.

Consideraciones Previas: Sobre el Contrato Administrativo

- 6.7 Debemos tener en cuenta que el contrato que vincula a las partes, dentro del marco de la ley de contrataciones con el estado, es eminentemente un contrato celebrado con la

administración pública y, por ende, conforme a la construcción doctrinaria, se le denomina como contrato administrativo, que en palabras del tratadista GUZMÁN NAPURÍ¹, contrato administrativo es:

"... Puede definirse el contrato administrativo como aquel en que la Administración ejerce prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo". (Énfasis agregado)

En esa misma línea, resulta importante entender el origen de lo que se conoce como contrato administrativo, para lo cual citaremos a GASPAR ARIÑO ORTIZ², quien nos dice que, en un Estado de Derecho, el Estado tiene dos formas de ejercer sus funciones, la primera mediante actos y procedimientos unilaterales cabe resaltar que en dicho primer supuesto actúa como poder y ejerce su autoridad, es decir estamos ante el *Ius Imperium*. Sin embargo, en otros momentos el Estado requiere contar con el concurso de iniciativas privadas y para ello recurre a un instrumento creado en el seno del Derecho Civil: el contrato, el cual vendría a ser la segunda forma en la que la administración pública busca ejecutar sus funciones.

- 6.9 Ahora bien, analizando lo que significa el contrato desde un punto de vista netamente civilista, podremos definirla como el acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de índole patrimonial, siendo que en el ámbito civil la voluntad de las partes tiene una esencial importancia para definir lo que vendría a ser el esquema contractual, estableciéndose que el contrato es una relación horizontal entre las personas que integran el pacto. Lo que en otros términos se definiría que para el Derecho Civil los contratantes son iguales.
- 6.10 Para el caso de los contratos administrativos, no podemos considerar al contrato administrativo como un contrato eminentemente civil, donde existe una relación horizontal y como consecuencia lógica las comunicaciones que efectúe la administración pública son meras comunicaciones o actos de gestión, puesto que la administración pública actuaría como un ente privado³; dejando de lado aspectos intrínsecos de Derecho Público que son inherentes a todo contrato administrativo.
- 6.11 Al respecto, DANÓS ORDÓÑEZ⁴ nos dice que, dentro de un contrato administrativo existe un elemento que le da una naturaleza distinta a la de un contrato civil y la denomina **prerrogativa**; definiéndola como el poder unilateral atribuido a la

¹ GUZMAN NAPURI, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General (2005). Pág. 320.

² ARIÑO ORTIZ, Gaspar. El Enigma del Contrato Administrativo (2007). Pág. 86 – 87.

³ GARCÍA TREVIJANO, José Antonio. Los Actos Administrativos. Civitas. Madrid, 1986. Pág. 43.

⁴ DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. El Régimen de los Contratos Estatales En El Perú. En Derecho Administrativo Contemporáneo. Ponencias del II Congreso de Derecho Administrativo. Palestra, Lima, 2007. Pág. 94.

Administración dentro de una relación contractual que le permite tener una posición prevalente.

- 6.12 En ese orden de ideas se establece que el hecho de participar en un contrato, no hace que la administración pública abandone o se despoje de su *ius imperium*, para someterse a un esquema de contratación netamente civilista, donde se presume la existencia de igualdad de condiciones de las partes, consecuentemente con ello no puede establecerse que exista una relación horizontal entre las partes contratantes y en tal sentido los pronunciamientos que ocurran entre éstas sean netamente actos de gestión contractual, tal como menciona el tratadista HUAPAYA TAPIA⁵:

"(...) En dicho contexto, de acuerdo a lo expresado por la doctrina sobre la materia, podemos denotar que la doctrina es pacífica en conceptualizar las potestades y prerrogativas de la administración pública como instrumento garantista del interés público que se circunscribe al objeto del contrato, en los cuales se pone de manifiesto las atribuciones de "privilegios", "poder" y "actuaciones unilaterales" en la relación contractual frente al co - contratante, quien se encuentra en una situación de subordinación jurídica a las "cláusulas exorbitantes" o frente al pliego normativo que les atribuye poder contractual..." (Énfasis agregado)

- 6.13 Estando a lo expuesto, en un contrato administrativo, tal como lo es el Contrato N° 004-2023-MDH/GM de fecha 11 de diciembre del 2023, la administración pública conserva para sí, su potestad y poder frente al demandante y en virtud de ello, puede ejecutar actuaciones unilaterales, las cuales de incidir sobre los derechos y obligaciones de éste o causar estados jurídicos, **constituirán indefectiblemente un acto administrativo**, tal como lo vienen a ser los actos sometidos a controversia y demás sustentos emitidos por la MUNICIPALIDAD.
- 6.14 Atendiendo a ello, las actuaciones que efectúe el Estado son considerados como actos administrativos y por ende, sujetos y regulados por la LPAG y la Ley, lo cual no implica un desconocimiento del orden de prelación previsto en el numeral 45.10 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo cumplir los requisitos exigidos en los citados dispositivos, siendo así, se procederá con el análisis del caso exigiendo el cumplimiento de los requisitos de debida motivación y competencia, previstos en el artículo 3° de la LPAG; siendo que en relación al debido procedimiento, el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA que dice:

⁵ HUAPAYA TAPIA, Ramón. Potestades y Prerrogativas en los Contratos Públicos en el Derecho Peruano. en: Aportes para un Estado Eficiente. Ponencias del V Congreso Nacional de Derecho Administrativo. Palestra, Lima. 2012. Pág. 542.

“... 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal...” (Énfasis agregado)

Consideraciones Previas: Sobre la Resolución del Contrato, requisitos y procedimiento

- 6.15 Tal como señalan MORÓN URBINA y AGUILERA B.⁶, la resolución del contrato es una forma de terminación anticipada del contrato, y se produce cuanto una de las partes falta al cumplimiento de sus prestaciones, pese haber sido requerido previamente para que subsane su incumplimiento, o se torna imposible, de manera definitiva, su continuación por caso fortuito o fuerza mayor.
- 6.16 Como podrá advertirse, la resolución del contrato es una potestad que tienen las partes de extinguir la relación contractual existente entre ellas, a consecuencia del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones establecidas o por situaciones ajenas e irreversibles a su voluntad que impidan la continuación del contrato, tal como dice el artículo 36° de la LCE:

“... Artículo 36. Resolución de los contratos

36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley...” (Énfasis agregado)

⁶ MORÓN URBINA, Juan Carlos y AGUILERA B., Zita. Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal- Colección Lo Esencial del Derecho N° 9. Fondo Editorial de la PUCP. 1° Edición. Lima-Perú. 2017. Pág. 160.

6.17 Además, dicha potestad solo podrá ser ejercida siempre y cuando exista una causal debidamente comprobada y siguiendo el procedimiento establecido por los artículos 164° y 165° del RLCE, que prescriben:

... Artículo 164. Causales de resolución

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

- a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
- b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
- c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el art. 165.

164.3. En los contratos de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades del supervisor comprenden la liquidación del contrato de obra, el supervisor puede resolver el contrato en los casos en que existe una controversia que se derive de la liquidación del contrato de obra.

164.4. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato

165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.

165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En

estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato

165.5. Cuando la resolución se sustente en alguno de los supuestos establecidos en el numeral 164.4 del artículo 164, la parte que resuelve debe comunicar su decisión mediante carta notarial justificando y acreditando los hechos que la sustentan.

165.6. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.

165.7. Tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del contrato regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico. En estos casos, no es necesario comunicar la decisión mediante carta notarial..." (Énfasis agregado)

6.18 En esa misma línea y siguiendo la posición de MORÓN URBINA y AGUILERA B.⁷, respecto a la resolución del contrato por la entidad contratante, resulta importante tener en cuenta que la entidad puede dar por concluido el contrato por culpa del contratista si este incurre en incumplimiento de obligaciones contractuales o legales - engaño en el material empleado, falsas mediciones de avances, negligencia en el cumplimiento del servicio, no alcanzar los rendimientos o índices de servicios, no iniciar prestaciones, ceder contrato, subcontratar sin autorización- o si paraliza o reduce injustificadamente la ejecución de la prestación mediante el abandono o interrupción de trabajos o si acumula el máximo de penalidad por mora.

6.19 En esa línea y, dado que el CONTRATO es uno con prestaciones recíprocas, debe tenerse en cuenta que, tal como describe el fundamento tercero de la Casación N° 534-2013/LIMA NORTE, nuestro ordenamiento jurídico prevé hasta tres modalidades de resolución por incumplimiento en los contratos con prestaciones recíprocas:

- a) La resolución judicial prevista en el artículo 1428° del Código Civil.
- b) La resolución por intimación o llamada también por autoridad del acreedor, regulada en el artículo 1429° del Código sustantivo.
- c) La resolución por cláusula resolutoria expresa o denominada pacto comisorio, prevista en el artículo 1430° del mismo Código.

⁷ Ob. Cit. Pág. 161

6.20 Conforme a ello, la resolución del contrato previsto en el art. 164° del RLCE tiene su parangón en la resolución por cláusula resolutoria expresa o denominada pacto comisorio, prevista en el artículo 1430° del Código Civil, respecto a lo cual VÁSQUEZ OLIVERA⁸ nos aclara que el pacto comisorio o cláusula resolutoria expresa, es una cláusula del contrato con prestaciones recíprocas en virtud del cual se conviene que el contrato quedará resuelto cuando una o cualquiera de las partes no ejecuta determinada prestación a su cargo, agregando que la cláusula resolutoria expresa constituye un mecanismo resolutorio que ha sido diseñado para lograr la resolución de un contrato de manera expeditiva sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

6.21 Así también, ORTEGA PIANA⁹ nos indica que, para la viabilidad jurídica de la resolución por incumplimiento, deben observarse rigurosamente (dado el efecto jurídico que se pretende que es la extinción del vínculo contractual) dos requisitos: la **legitimidad resolutoria y el procedimiento resolutorio**; indicando:

“... La legitimidad permite responder una cuestión elemental: ¿Puede resolverse el contrato? Al respecto, presenta dos componentes. Uno subjetivo, asociado a la noción de parte fiel, y otro objetivo, relativo a que el incumplimiento invocado sea grave, significativo o relevante.

El primer componente de la legitimidad

*El acreedor que opta por resolver la relación obligatoria derivada del contrato, en el contexto de un acuerdo sinalagmático, **debe ser el contratante fiel**, entendiéndose como tal al deudor que ya cumplió con la prestación a su cargo (lo que podemos calificar como una lectura positiva del requisito) o al deudor que no ha faltado al cumplimiento de la prestación a su cargo (lectura negativa), por ser aún **inexigible** (...)*

Si partimos de la premisa que todo contrato no es sino un acuerdo de distribución de riesgos, se debería considerar los alcances de la obligación, dado que algunas obligaciones son nucleares o esenciales, y otras son meramente secundarias y operan de manera independiente a las anteriores. Si lo que se ha incumplido es una obligación fundamental en el desarrollo o dinámica sinalagmática, resultaría muy razonable sostener que el deudor de la misma, desempeñándose como acreedor de una obligación esencial, carecerá de legitimidad para resolver. Empero, si se trata de un incumplimiento meramente colateral, sí debería entenderse que el respectivo deudor, cuando se desempeña en el rol del acreedor de una obligación de mayor relevancia o trascendencia negocial, sí estaría habilitado para resolver, en la medida que la obligación correspondiente hubiese sido cumplida o no sea todavía exigible su cumplimiento. Y es que, en términos sencillos, ese

⁸ VÁSQUEZ OLIVERA, Salvador. “Derecho Civil –Definiciones” Ediciones Jurídicas del Sur. Arequipa- Perú. 1ª Edición. 1990. págs. 433 y 552

⁹ ORTEGA PIANA, Marco Antonio. Pacto Resolutorio Expreso- Algunos Comentarios sobre su Regulación Civil y Registral. *Giuristi: Revista de Derecho Corporativo*. 4(8), 3–47. <https://doi.org/10.46631/Giuristi.2023.v4n8.02>. Pg. 12-16

eventual incumplimiento no afecta al desarrollo o dinámica de ejecución correlativa del negocio común, esto es, al sinalagma del contrato. (...)

El segundo componente de la legitimidad

No basta que el acreedor que opta por resolver sea parte fiel, sino que además se requiere que el incumplimiento incurrido por la parte infiel sea uno significativo, grave. Sobre el particular, es aplicable lo ya expresado en el anterior trabajo, en particular sobre la necesidad de realizar una interpretación sistemática del Código Civil, dado que en sus reglas generales de contratación no hay mención expresa a este componente que viabiliza a la resolución por incumplimiento, a diferencia de lo que sí contemplan sus reglas sobre contratación típica. La resolución es un remedio extremo, por lo que no se justifica aplicarlo por nimiedades. El incumplimiento debe ser significativo, atendiendo a la afectación del interés del acreedor. Si partimos de la regla de la buena fe, y que el contrato es un medio de satisfacción inmediata de intereses de las partes, pero mediata de los intereses de la sociedad por el tema que el contrato facilita el tráfico patrimonial, este segundo componente bajo comentario está más que justificado. Atendiendo a la autonomía privada (a la autorregulación), debe entenderse que la gravedad se define por las propias partes; en su defecto, debería considerarse a las obligaciones esenciales, nucleares o fundamentales del negocio celebrado, aplicándose supletoriamente la ley. El problema surge, en la práctica, cuando corresponde evaluar si una determinada obligación es nuclear o no, atendiendo a lo que las partes se hubiesen representado o lo que es representable en general. Se aprecia, por consiguiente, que se está ante un tema que podría derivar en un contencioso..."

Análisis del presente caso:

- 6.22 Ahora, en el marco de la pretensión materia de análisis, la suscrita advierte que es relevante determinar, a efectos de llegar a una conclusión concreta respecto a cada una de las materias sometidas a análisis, si es que se cumplieron las condiciones necesarias para que la resolución contractual sea válida. En este análisis, esta Árbitro Único evaluará las posiciones vertidas por ambas PARTES, por un lado, la del CONSORCIO que señala que cumplió con sus obligaciones contractuales, correspondiendo que su contraparte ejecute la contraprestación respectiva; y el de la ENTIDAD, que considera que su contraparte no ha cumplido con la correcta ejecución de sus obligaciones.
- 6.23 En la medida que lo pretendido por el CONSORCIO es que se declare sin efecto la resolución contractual efectuada por la MUNICIPALIDAD a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM de fecha 14 de agosto de 2024 y Carta Notarial N° 008-2024-MDH-GM; por otro lado, es la posición de la MUNICIPALIDAD que se declare la validez de la resolución del CONTRATO efectuado ante el

incumplimiento de obligaciones por parte del CONSORCIO. De manera que la Árbitro Único considera necesario, preliminarmente, verificar si efectivamente la resolución contractual planteada por la MUNICIPALIDAD ha cumplido con la formalidad que exige la normativa del caso.

6.24 Es así que, si bien ninguna de las PARTES ha ofrecido el mérito probatorio de la Carta Notarial N° 001-2024-MDH-GM de fecha 07 de mayo del 2024, con la que se apercibe al CONSORCIO al cumplimiento de sus obligaciones, lo cierto que la existencia de dicho documento ha sido reconocida expresamente por el CONSORCIO mediante el numeral 17 del escrito de su demanda:

17.- Que, a través de la CARTA NOTARIAL N°001-2024-MDH-GM, de fecha 07 de mayo de 2024, la Municipalidad Distrital de Huácar, solicita cumplir sus obligaciones contractuales, la misma que fue absuelto mediante Carta N°003-2024-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL de fecha del 10 de mayo de 2024, sustentando haber cumplido con el Servicio: "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, DEARTMAENTO DE HUANUCO". Solicitando se emita la RECEPCIÓN DEL SERVICIO, debido que mi representada ha cumplido con sus obligaciones contractuales para con la entidad;

6.25 Siguiendo la misma línea, con fecha 20 de agosto del 2024, la MUNICIPALIDAD comunica al CONSORCIO la Carta Notarial N° 008-2024-MDH-GM, adjuntando a su vez la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM de fecha 14 de agosto de 2024, mediante la cual decide resolver en forma total el CONTRATO, por incumplimiento de obligaciones y por haber acumulado el monto máximo de penalidades.

6.26 Conforme a ello, de los actuados obrantes en el presente expediente arbitral y que fueran ofrecidos por las PARTES, se tiene que la MUNICIPALIDAD ha ejercido su derecho de resolver el CONTRATO, aplicando para ello el procedimiento descrito por los numerales 165.1 y 165.3 del RLCE, en el sentido que:

- a) Ante la falta de cumplimiento de sus obligaciones, la MUNICIPALIDAD le requirió notarialmente (Carta Notarial N° 001-2024-MDH-GM de fecha 07 de mayo del 2024) al CONSORCIO que las ejecute, otorgándole para ello el plazo de 05 días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, tal como manifestó la propia DEMANDANTE.
- b) Vencido el plazo otorgado, empero, con la continuidad del incumplimiento, la MUNICIPALIDAD optó por resolver el CONTRATO empleando para ello la Carta Notarial N° 008-2024-MDH-GM (notificada el 20 de agosto del 2024),

adjuntando la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM que contiene el acto administrativo de la decisión de la entidad pública.

Conforme a ello, a la luz de la causal invocada para la resolución del contrato y de la documentación sustentaría aparejada en autos, se tiene que la MUNICIPALIDAD si cumplió con el procedimiento establecido.

Habiéndose revisado el cumplimiento formal del procedimiento de resolución contractual por parte de la MUNICIPALIDAD, esta Ábitro Único estima necesario pasar a revisar los hechos ocurridos con posterioridad a la suscripción del contrato, a fin de realizar un análisis en conjunto que pueda determinar si la resolución contractual se encontraba o no debidamente justificada.

6.29 Para tal efecto, corresponde verificar si es que la decisión de resolver el contrato encuentra su sustento, es decir, corresponde verificar si el CONSORCIO habría incurrido o no en los incumplimientos descritos por la MUNICIPALIDAD; por lo que, revisadas las razones por las cuales la MUNICIPALIDAD comunicó al CONSORCIO la resolución contractual, de la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM se evidencia que la misma se sustentó en los siguientes hechos:

Que, de lo antes expuesto, en el presente caso se deberá de resolver el contrato con el CONSORCIO HUACARMAYO, por lo siguiente:

- La ejecución del servicio: **"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO"**, se ha llevado a cabo sin advertencia, deficiencia y/o defectos del expediente técnico debido a que la entidad desconoce hasta el momento cualquier comunicado del profesional para gastos de control y cierre de la actividad de limpieza o autorización alguna por mejoras a la prestación del presente servicio.
- *El servicio ha sido ejecutado por la modalidad de suma alzada, y a pesar de haber aprobado un adicional no se respetó las metas del servicio como también no existe algún pronunciamiento del proyectista de la aprobación del adicional.*
- De lo señalado en los dos párrafos anteriores, sobre las deficiencias en su momento de ejecución del servicio nunca evidenciaron a fin de que pueda subsanar a través de varios parámetros técnicos y legales, más de lo contrario trataron de cumplir con sus obligaciones con deficiencias y/o defectos del expediente técnico, tal como señala la Unidad de Obras.
- Por último, el contratista no solicitó de manera formal la culminación del servicio a la entidad, de lo contrario habría presentó fuera de plazo la recepción del servicio (23/04/24), ya que como fecha máxima se tenía al 05 de enero del 2024, y por ende se evidencia que supera el 10% de máxima penalidad, según el informe técnico del área usuaria, ya que habría llegado a acumular el máximo de penalidades.

6.30 A continuación, la suscrita procede a revisar la razonabilidad y el sustento de las causales invocadas para la resolución contractual, de la siguiente manera:

6.30.1. La MUNICIPALIDAD justifica su decisión señalando que *"la ejecución del servicio se llevó a cabo sin advertencia, deficiencia y/o defectos del expediente técnico debido a que la entidad desconoce cualquier comunicado del profesional para gastos de control y cierre de la actividad de limpieza o autorización alguna por mejoras a la prestación del servicio"*; al respecto, se entiende que la MUNICIPALIDAD indica que el CONSORCIO no cumplió con advertir de deficiencias y/o defectos del expediente técnico, ya que el personal clave respectivo no realizó la comunicación pertinente; ahora, el art. 32.7 de la LCE precisa que **la responsabilidad por la adecuada formulación del Expediente Técnico** o Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión, de acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y la aprobación a la Entidad, de igual modo, **la entrega completa de la información que es puesta a disposición de los postores, corresponde a la Entidad.** En esa misma línea, el Art. 41.2 del RLCE nos indica que, tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras **se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico** y la disponibilidad física del terreno, salvo que, por las características de la obra, se permita entregas parciales del terreno. Para ahondar aún más en el tema queremos citar a SOLOGUREN CALMET (2018)¹⁰ quien, al referirse sobre el expediente técnico de una obra, señala:

"... Para tener un contexto adecuado, debemos considerar que el modelo de construcción (o project delivery system) adoptado por el Estado, en el marco del RLCE es el sistema tradicional, a partir del cual el propietario (Estado) comúnmente contrata a un tercero para que elabore el expediente técnico (ingeniería para construir) y luego lo aprueba.

Una vez aprobado el expediente técnico, el Estado convoca los procesos de selección respectivos para que se contrate al ejecutor de la obra, quien, una vez que ha obtenido la buena pro y ha suscrito el contrato, debe ejecutar la obra de conformidad con lo establecido en el expediente técnico que le fue entregado por la entidad pública correspondiente.

Así, tenemos que el contratista ejecutor no ha intervenido en la elaboración del expediente técnico, incluso del modo cómo está organizado el RLCE no puede

¹⁰ SOLOGUREN CALMET, Hugo. Implicancias de la revisión del expediente técnico de obra contemplado en el Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Artículo publicado en la Revista "Cuadernos Jurídicos Ius ET Tribunales". Año 4, Número 4. Huancayo-Perú. 2018. Pág. 112-114 (<https://journals.continental.edu.pe/index.php/iusettribunalis/issue/view/54>)

proponer mejoras al expediente técnico en la etapa del proceso de selección, solo puede observarlo. Ahora, bajo este esquema, **el Estado es el responsable de la elaboración y aprobación del expediente técnico (denominado también como proyecto definitivo o ingeniería de detalle)**. El proyecto definitivo contiene los planos generales, los planos de detalle, las especificaciones técnicas, las memorias de cálculo, las bases de la licitación y elaboración de presupuestos. En consecuencia, el proyecto debe contener todos los antecedentes que permitan la ejecución de la obra (Molina y Rios, 2016, p. 118).

En el esquema del sistema tradicional adoptado por el Estado se encuentra marcada la asignación de riesgos. Así, quien debe responder por las deficiencias del expediente técnico o proyecto definitivo es el propietario de la obra (el Estado), siendo el responsable de las deficiencias de la ejecución de la obra el contratista..."

Queda claro entonces que el expediente técnico de una obra pública, se constituye en un cuerpo documentado que contiene las condiciones técnicas multidisciplinarias del proyecto, siendo ente rector de las actividades que realizará el contratista y **cuyo único responsable de su elaboración, actualización y entrega es la entidad**. Ahora bien, dicha responsabilidad trae consigo la obligación de la entidad de hacer entrega de dichas condiciones técnicas como requisito previo a la convocatoria del procedimiento de selección, ya que esto permitirá que los postores conozcan los alcances, dimensiones y demás condiciones técnicas del proyecto, y, como es lógico, sin ella sería imposible continuar con la contratación de la obra.

Conforme a ello, si bien el CONSORCIO tiene el deber de "colaborar" para identificar errores o defectos del expediente técnico, empero, ello no implica que se le traslade **la responsabilidad** por su **adecuada formulación** ya que, como dijimos, la misma recae única y exclusivamente sobre la MUNICIPALIDAD, ya que como señala ORDOQUI CASTILLA "el deber de colaboración leal en la ejecución del contrato entre las partes exige al acreedor abstenerse de todo acto u omisión que pueda tener por consecuencia privar a la otra parte de beneficios o ventajas propias del contrato o que agrave injustificadamente el resultado, volviendo más onerosa la situación del deudor"¹¹; por tal motivo, resulta desproporcionado que se impute incumplimiento de obligaciones no atribuibles al CONSORCIO.

Sumado a ello, de la revisión de autos se advierte que el CONSORCIO **si**

¹¹ ORDOQUI CASTILLA, Gustavo. Buena fe contractual. Bogotá: Ed. Pontificia Universidad Javeriana –Universidad Católica de Uruguay – Ibáñez, 385 (2012).

cumplió con advertir oportunamente sobre deficiencias y/o defectos del expediente técnico, que derivaron incluso en la aprobación mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 302-2023-MDH/GM del 22 de diciembre de 2023, del Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01.

Con todo ello, para la Arbitro Único ha quedado demostrado que la causal invocada por la MUNICIPALIDAD para resolver el contrato, deviene en infundada.

6.30.2. Se señala también que "el servicio ha sido ejecutado por la modalidad de suma alzada, sin embargo, a pesar de haberse aprobado un adicional no se respetó las metas del servicio, así como tampoco existe pronunciamiento del proyectista de la aprobación del adicional"; al respecto, si bien la MUNICIPALIDAD asevera el incumplimiento en la ejecución de las metas del servicios, empero, de la revisión de los medios probatorios aportados por las partes se tiene el "Acta de Recepción de Obra-Pliego de Observaciones" de fecha 26 de enero del 2024, la misma que indica las siguientes observaciones a la ejecución del servicio:

PLIEGO DE OBSERVACIONES:

- Las dimensiones que muestran los planos originales, planilla de metrados, descripción del proyecto y el terreno real. Son diferentes
- Modalidad de ejecución:
A Suma Alzada. Por su naturaleza de la obra debería haber sido a Precios Unitarios
- De las secciones y longitudes intervenidas:

Cuadro de Vulnerabilidad:

PROG.	ANCHO (en metros)		TI GRANPO	OBSERVACIONES
	PROYECTO	ACTUALIZADO		
0+000		9.30	9.00	Metas iniciales del Proyecto.
0+100		9.40	9.00	Limpieza y descolmatación del cauce del río huacarmayo, conformación de Talud Lateral (con material propio) y Eliminación de material excedente.
0+200		9.63	9.00	
0+300		9.64	9.00	
0+400		9.80	9.00	En el marco de los numerales 34.1 y 34.2 del artículo 34 de la Ley, la Entidad aprobó con Resolución de Gerencia Municipal N° 302-2023-MDH/GM prestaciones por "diferencias" entre el expediente técnico y el terreno real, referente a características iniciales del proyecto (longitud inicial y secciones transversales del área de intervención con maquinaria pesada) sin haber afectado el equilibrio presupuestal ni el principio de equidad.
0+500		9.98	9.00	
0+600		9.71	9.00	
0+700		9.75	10.00	
0+800		15.00	12.00	
0+900		11.94	12.00	El ancho del cauce intervenido mayormente es menor del ancho mencionado en los planos modificados en el expediente técnico del Adicional N° 1 y Deductivo N° 1
1+000	24.00	26.51	20.00	
1+100	24.00	19.90	20.00	De igual manera, el área presenta "islas" conformado por piedras que fueron acomodadas pero que, ante una crecida extraordinaria del caudal, ingreso de huaycos y otros movimientos de masa, podría conformar un obstáculo y causar embalsamientos y posibles desbordes que justamente se quiere evitar
1+200	24.00	16.53	11.00	
1+300	24.00	14.63	12.00	
1+400	24.00	12.47	9.00	El objetivo es la prevención y reducción de riesgos en la localidad de Huacar, a través de la intervención con maquinaria pesada en el cauce del río Huacarmayo, por lo que; el contratista deberá mejorar la limpieza y descolmatación del cauce tomando en cuenta las obras hidráulicas existentes
1+500	24.00	11.68	9.00	
1+600	24.00	9.87	9.00	
1+700	24.00	9.64	9.00	
1+800	24.00	10.46	10.00	
1+900		11.29	11.00	
2+000		12.73	12.00	
2+040		11.64	13.00	

- El Comité de Recepción de Obra, en cumplimiento de su conducta procedimental y transparencia concluye que, las metas iniciales del proyecto no fueron cumplidas eficientemente.
- Entre las secciones 0+500 (sección 1) hasta la 2+100 (final reformulado del tramo), la sección transversal del cauce del río es variada y su intervención (limpieza, descolmatación, eliminación de escombros y conformación de talud lateral) con maquinaria pesada, no fueron ejecutadas eficientemente, por lo que, el contratista deberá reintervenir en dicho tramo realizando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida por la Entidad según los Términos de Referencia. Cabe destacar que, durante el levantamiento de observaciones el contratista deberá tomar en cuenta las obras hidráulicas existentes en el lugar sin llegar a afectarlos, así mismo deberá tomar en cuenta que no se deben formar "islas" que pudieran obstaculizar el libre desplazamiento de volúmenes extraordinarios de agua, todo y material acarreado por las lluvias de temporada.

Como podrá observarse, el documento en referencia si bien contempla "observaciones" a la ejecución del servicio, empero, la formulación de observaciones no implica la inejecución de metas pues lo único que demuestran es que las prestaciones se ejecutaron sin el cumplimiento estricto de las características, dimensiones o la calidad de los servicios contratados; además, ante el incumplimiento de subsanar las observaciones la MUNICIPALIDAD tenía expedito su derecho de aplicar las penalidades previstas por el contrato, empero, lo que la MUNICIPALIDAD argumenta es que no se ejecutaron las prestaciones establecidas por el Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01, lo que, como ya dijimos, es erróneo ya que el CONSORCIO si llegó a ejecutar tales partidas aunque con observaciones.

Finalmente, respecto al argumento de que tampoco existe pronunciamiento del proyectista sobre la aprobación del adicional, resulta evidente que un hecho o actuación atribuible a un tercero como es el proyectista, no puede ser atribuido al CONSORCIO, ya que este ultimo solo responde por las acciones u omisiones propias.

Con todo ello, para la Arbitro Único ha quedado demostrado que la causal invocada por la MUNICIPALIDAD para resolver el contrato, deviene en infundada.

- 6.30.3. Señala también "que, de lo mencionado en los párrafos anteriores, sobre las deficiencias en su momento de ejecución del servicio, nunca evidenciaron a fin de que pueda subsanar, a través de varios parámetros técnicos y legales, al contrato trataron de cumplir con sus obligaciones con deficiencias y/o defectos del expediente técnico, tal como señala la Unidad de Obras de la entidad"; Al respecto, como ya indicamos previamente, si bien el CONSORCIO tiene el deber de "colaborar" para identificar errores o defectos del expediente técnico, empero, ello no implica que se le traslade la responsabilidad por su adecuada formulación ya que, como dijimos, la misma recae única y exclusivamente sobre la MUNICIPALIDAD, ya que el deber de colaboración leal en la ejecución del contrato entre las partes exige al acreedor abstenerse de todo acto u omisión que pueda tener por consecuencia privar a la otra parte de beneficios o ventajas propias del contrato o que agrave injustificadamente el resultado, volviendo más onerosa la situación del deudor"; por tal motivo, resulta desproporcionado que se impute incumplimiento de obligaciones no atribuibles al CONSORCIO. Sumado a ello, de la revisión de autos se advierte que el CONSORCIO si cumplió con advertir oportunamente sobre deficiencias y/o defectos del expediente técnico, que derivaron incluso en la

aprobación mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 302-2023-MDH/GM del 22 de diciembre de 2023, del Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01.

Con todo ello, para la Arbitro Único ha quedado demostrado que la causal invocada por la MUNICIPALIDAD para resolver el contrato, deviene en infundada.

6.30.4. Finalmente, indica que *"el contratista no solicitó de manera formal la culminación del servicio a la entidad, al contrario, habría presentado fuera de plazo la recepción del servicio (23/04/2024) ya que como fecha máxima se tenía al 05/01/2024, por ende, se evidencia que supera el 10% de máxima penalidad, según el informe técnico del área usuaria, ya que habría llegado a acumular el máximo de penalidades"*; Al respecto, el RLCE en su numeral 161.2 del artículo 161° ha establecido que la entidad puede prever la aplicación de dos tipos de penalidades: la penalidad por mora y otras penalidades; así también, señala que estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Por lo tanto, la entidad no podría aplicar penalidades por encima del tope máximo señalado por la norma. Así también, el RLCE en su numeral 161.1 del artículo 161°, ha señalado que el contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son **objetivas, razonables y congruentes** con el objeto de la convocatoria; al respecto, la Opinión N° 023-2017/DTN nos da mayor alcance respecto a tales criterios indicando que:

- i) La objetividad implicaba que la Entidad establezca de manera clara y precisa los tipos de incumplimiento que serían penalizados, los montos o porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento, y la forma o procedimiento mediante el que se verificaría la ocurrencia de tales incumplimientos, según la naturaleza y características particulares de cada contratación;
- ii) Por su parte, la razonabilidad implicaba que cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que se aplicarían al contratista sean proporcionales a la gravedad y reiteración del incumplimiento, y;

- iii) La congruencia con el objeto de la convocatoria implicaba que se penalizara el incumplimiento de alguna obligación comprendida o relacionada con el objeto de la convocatoria.

De igual forma, la Opinión N° 005-2023/DTN ha señalado que:

"... 2.1.2. Precisado lo anterior, resulta oportuno anotar que, para el caso de contratos de ejecución de obra, el numeral 161.3 del artículo 161 del Reglamento dispone que dentro de las otras penalidades que se establecen en las bases se incluyen también las previstas en el capítulo VI del título VII del Reglamento.

Ahora bien, cabe mencionar que conforme a lo dispuesto en el numeral 162.1 del artículo 162 del Reglamento, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato -situación que puede producirse en el marco de un contrato de obra pública- la Entidad le aplica "automáticamente" una penalidad por mora por cada día de atraso.

En ese contexto, se aprecia que el mencionado dispositivo establece, expresamente, que la penalidad por mora se aplica de manera automática (al haberse configurado el atraso injustificado del contratista), y se calcula de acuerdo a la formula prevista en el mencionado numeral.

2.1.3. Sobre el particular, es pertinente anotar que la penalidad por mora que regula la normativa de Contrataciones del Estado se aplica al contratista cuando se configura un "retraso injustificado" en la ejecución de las prestaciones a su cargo, lo que tratándose de un contrato de obra se configura cuando cumplido el plazo de ejecución contractual establecido, la obra no ha sido culminada.

Al respecto, el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento dispone que el retraso se podría justificar de dos maneras: i) con la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo; o, ii) con la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad, la cual resulta de la acreditación, objetivamente sustentada por el contratista, de que el mayor tiempo transcurrido (en la ejecución de las prestaciones a su cargo) no le resulta imputable a éste último.

En ese sentido, se advierte que la situación de incumplimiento contractual que configura un retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista genera, a su vez, la aplicación automática de la penalidad por mora, conforme a lo establecido en el artículo 161 del Reglamento; hecho que supone la evaluación previa y determinación correspondiente, por

parte de la Entidad, que el retraso es injustificado y, en consecuencia, corresponde la aplicación de dicha penalidad..." (Énfasis agregado)

Conforme a ello y atendiendo al Principio de Transparencia¹² indicado en el inciso c) del artículo 2° de la LCE, acorde con el criterio de objetividad de las penalidades y lo indicado por la Opinión N° 005-2023/DTN, se puede asegurar que para el caso de la penalidad por mora, el artículo 162° del RLCE ha establecido que la misma es de "aplicación automática", **es decir que no se presume sino que necesariamente debe ser aplicada a la relación jurídica existente entre ambas partes**, lo cual implica que necesariamente se debe haber realizado las siguientes acciones: i) Que la entidad haya evaluado si los retrasos son injustificados; ii) Que la entidad haya calculado el monto y porcentaje de las penalidades, acorde con el numeral 162.1 del artículo 162° del RLCE; y iii) Que se haya notificado al contratista la aplicación de la penalidad, a fin que ejerza su derecho a la defensa.

Conforme a ello, si bien la MUNICIPALIDAD señala que el CONSORCIO habría superado el tope máximo del 10% de penalidades, sin embargo, en autos no se advierte documento alguno que acredite la aplicación de algún tipo de penalidad, es más, del recurso de contestación de la demanda tampoco se argumentado la aplicación de penalidades, razón por la cual no se puede intuir, presumir o deducir que el CONSORCIO tenga penalidades aplicadas en su contra, ya que ello vulneraría el criterio de objetividad de las mismas.

Con todo ello, para la Arbitro Único ha quedado demostrado que la causal invocada por la MUNICIPALIDAD para resolver el contrato, deviene en infundada.

- 6.31 Conforme a ello, y habiéndose determinado que las causales invocadas por la MUNICIPALIDAD para resolver el contrato, son infundadas o insuficientes, para la suscrita queda claro que la resolución contractual efectuada con Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM y Carta Notarial N° 008-2024-MDH-GM, devienen en actos nulos e inválidos, ya que han sido emitidas sin haberse respetado el procedimiento establecido para su procedencia, razón por la cual la pretensión debe de ser amparada en su totalidad.

¹² Principio de Transparencia: Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

336
Presidentes
tribunales y SOC

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que, el Árbitro Único ORDENE a la Municipalidad Distrital de Huácar mantenga los efectos jurídicos en el caso de la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM, de fecha 14 de agosto de 2024, ORDENE a la Municipalidad Distrital de Huácar mantenga y/o restablezca el STATU QUO del Contrato N° 004-2023-MDH/GM, suscrita el 11 de diciembre de 2023, entre Consorcio Huacarmayo y la Municipalidad Distrital de Huácar. Asimismo, determinar si corresponde o no que el árbitro ORDENE la formalización de la recepción del servicio "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".

Posición del DEMANDANTE

6.32 Que, la DEMANDANTE señala:

"El Árbitro Único por los efectos jurídicos en el caso de DECLARAR LA NULIDAD y/o INEFICACIA de la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM, de fecha 14 de agosto de 2024, ordene a la Municipalidad Distrital de Huácar mantenga y/o restablezca el STATU QUO del Contrato N° 004-2023-MDH/GM, suscrita el 11 de diciembre de 2023, entre mi representada Consorcio Huacarmayo y la Municipalidad Distrital de Huácar. Y en consecuencia se ORDENE con la formalización de la recepción y conformidad del servicio "Limpieza y Descolmatación del Río Huacarmayo en la localidad de Huácar, Distrito de Huacar, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco"; en aplicación del art 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado".

22.- Que, mediante Carta N° 001-2024-WPRP/S, de fecha 04 de enero de 2024, la supervisión informo a la Entidad la culminación y solicito la conformación del comité para recepción de servicio. Siendo así con fecha del 26 de enero del 2024, se suscribe el Acta de Recepción de Servicio, con observaciones, en la cual se otorga un plazo de 6 días calendarios para el levantamiento de observaciones.

Que, dentro del plazo, con fecha del 01 de febrero del 2024, mediante asiento N° 30 del cuaderno de ocurrencias se señala la terminación del levantamiento de observaciones, solicitándose a la supervisión su trámite correspondiente y con asiento N° 31, la Supervisión confirma la subsanación, la cual mediante Carta N° 003-2024-WPRP/S, comunica a la entidad la culminación del levantamiento de observaciones y solicitando la nueva fecha de recepción del servicio. Asimismo, con fecha del 05 de febrero del 2024, presenta la supervisión la Carta N° 004-2024-WPRP/S, con los planos de replanteo final del servicio.

335
Presidentes
treinta y
cinco

23.- Que, a través de la Carta N° 02-2024-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL de fecha del 22 de abril de 2024, mi representada reitera la solicitud de recepción del servicio y conformidad del servicio

Que, con Informe N° 0591-2024-MDH/GIUDR, de fecha 26 de abril de 2024, el Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, recomienda solicitar al contratista CONSORCIO DESCOLMATACION HUACAR Mediante su profesional ING. Tony Edy Llanos Villareal, y al profesional para gastos de control y cierre de la actividad de limpieza al Ing. Williams Paul Rodríguez Palacios, remitir los actuados, informes, cartas y otros documentos en el cual evidencia las diferencias del expediente técnico comunicados a la entidad en su debida oportunidad;

24.- Que, el Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala:

168.1. *"La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.* 168.2. *La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractual les, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.* 168.3. *La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. El mismo plazo resulta aplicable para que la Entidad se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones, según corresponda.* 168.4. *De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Subsanas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades,* 168.5. *Cuando la Entidad exceda el plazo legal previsto para emitir la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los días de retraso no pueden ser imputados al contratista a efectos de la aplicación de penalidades (...)*

Como es de verse, el procedimiento de recepción y conformidad exige que la Entidad realice las verificaciones que correspondan, de acuerdo con la naturaleza de la prestación, sobre la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales,

Ahora bien, en el presenta caso se advierte que pesar de haber cumplido con el levantamiento de observaciones y de contar con el respaldo de la supervisión, el consorcio tuvo que reiterar su solicitud de recepción y conformidad mediante la Carta N° 02-2024-CONSORCIO HUACARMAYO/KJMP/RL del 22 de abril de 2024.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
GABRIELA LUCERO ECHEVERRÍA TAFUR
SECRETARÍA ARBITRAL

336
Trescientos
treinta y
seis

De ahí que, la demora injustificada de la entidad:

- El Informe N° 0591-2024-MDH/GIUDR del 26 de abril de 2024, emitido por el Gerente de Infraestructura de la Municipalidad, solicitó documentación adicional, generando una demora injustificada en el proceso de recepción, vulnerando los plazos establecidos en el Artículo 168 del Reglamento.

Ahora bien, la ejecución conforme al contrato

- El servicio contratado y el Adicional N° 01 - Deductivo N° 01 fueron ejecutados en su totalidad, alcanzando un total de 2,036 metros lineales de descolmatación, cifra que incluso supera la longitud original requerida de 1,210 metros lineales.
- Los trabajos fueron validados mediante valorizaciones, informes de la supervisión y planos de replanteo final.

Cuyo impacto positivo del servicio cumplió su objetivo de mitigar riesgos de desbordes e inundaciones durante la temporada de lluvias (diciembre 2023 a abril 2024), cumpliendo con el propósito definido por el FONDES (Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales).

Sin embargo, el cumplimiento de plazos por parte de la entidad, según el Artículo 168.5 del Reglamento, la entidad tenía un plazo de 7 días para emitir la conformidad o pronunciarse sobre las observaciones. Este plazo no fue respetado.

La demora en la recepción y conformidad no puede ser imputada al contratista ni justificar la resolución del contrato. Consecuentemente, se ha vulnerado el principio de buena fe contractual; toda vez que:

- La Municipalidad, a pesar de las reiteradas solicitudes y de contar con la documentación que acreditaba el cumplimiento del servicio, resolvió arbitrariamente el contrato sin una justificación válida.

Que, el artículo 168.4 del RLCE, establece que *“Las observaciones deben ser comunicadas al contratista de manera clara, con un plazo para subsanarlas. Una vez subsanadas dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades”*.

Asimismo, en su artículo 168.5: Dispone que *“La demora en la emisión de la conformidad por parte de la entidad no puede ser imputada al contratista ni justificar la aplicación de penalidades”*.

25.- Que, debe indicarse que, de acuerdo con el Anexo Único del Reglamento, “Anexo de Definiciones”, el cuaderno de obra: *“El documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas”*

Como puede apreciarse, el cuaderno de obra es un instrumento indispensable para la comunicación entre la Entidad y el contratista, y para el control de la obra, en tanto tenía por finalidad registrar los hechos relevantes ocurridos durante su ejecución para, entre otros fines, sustentar las solicitudes del contratista y las decisiones de la Entidad.

333
Trescientos
treinta y
tres

En aplicación supletoria, y conforme se encuentran establecidas en las bases integradas, el contratista se obliga durante la ejecución llevar un cuaderno de ejecución de servicio (...), donde se consignen los avances de los trabajos y ocurrencias;

Siendo así, y estando a las observaciones iniciales en la recepción del servicio, mi representada cumplió con los plazos establecidos para subsanar dichas observaciones, como lo confirma el Cuaderno de Ocurrencias y las cartas emitidas por la Supervisión. Este cumplimiento fue verificado y respaldado por la Supervisión, lo que demuestra que la ejecución del servicio fue conforme al contrato, y que la Municipalidad no cumplió con los procedimientos de recepción establecidos en la ley, lo que vulnera los principios contractuales.

Que, es necesario destacar que la actuación de la demandada vulnera principios esenciales del derecho administrativo, como el respeto a la voluntad contractual y el principio de buena fe, los cuales están consagrados tanto en la legislación sobre contratación pública como en la Constitución, proscribiéndose el abuso de derecho.

Deviene en necesario señalar que estando al proceso AS-DU-032-2023- M-1-2023-MDH//CS-1, cuyo servicio de descolmatación tiene como objetivo primordial la eliminación de escombros y piedras que se acumulan en el cauce de un río, así como la extracción de material acumulado que se encuentran en los lechos de ríos, canales y embalses. Esta actividad tiene la finalidad de mitigar y prevenir el desborde de los cauces fluviales

De acuerdo con el FONDES (FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES), entidad estatal encargada de financiar dicho servicio a través de la Municipalidad Distrital de Huácar, los trabajos de descolmatación de ríos y quebradas están diseñadas específicamente para reducir los riesgos de desbordes e inundaciones durante la temporada de lluvia. En este contexto, es importante señalar que la intervención ha cumplido con su objetivo durante la temporada de lluvias de diciembre de a abril del 2024 con total eficacia.

Asimismo, deviene en necesario mencionar que la vida útil de esta actividad de descolmatación está establecida es un año, periodo que ya ha sido cumplido.

Consecuentemente, mi representada ha cumplidos con las Obligaciones Contractuales para con la entidad, el mismo que conforme se acredita en anexos, se demuestra de manera clara y documentada que se ha ejecutado las actividades conforme a lo establecido en el expediente técnico y las modificaciones aprobadas. Las valorizaciones presentadas, junto con los informes de la supervisión y los planos de replanteo final, validan que los trabajos de descolmatación se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones contractuales, alcanzando un total de 2,036.00 metros lineales de descolmatación, lo que excede la cantidad requerida.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARIA ARBITRAL

332
Trescientos
treinta y
dos

Consecuentemente, la recurrida deviene en nula debido a que carece de fundamento y está viciada de irregularidades. La entidad no permitió la debida oportunidad de presentar pruebas sobre las modificaciones al expediente técnico, y actuó de manera inconsistente con lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que constituye un abuso de derecho. Este proceder vulnera el principio de buena fe y el respeto a los acuerdos contractuales, generando un perjuicio a mi representada.

De ahí, que la demandada con la finalidad desconocer y más aun de pretender omitir sus responsabilidades, sin sustento técnico y legal resuelve el contrato; el cual, a todas luces, vulnera el procedimiento específico para la recepción y conformidad del servicio, la misma que se encuentra revestido de una serie de formalidades, cumpliéndose a cabalidad conforme lo está establecido en las bases y en el contrato.

26.- Que, el Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del Capítulo IV del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que *"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"*;

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado ha contemplado el procedimiento que debe observarse para la recepción y conformidad del servicio, así como la forma en que se computan los plazos para tal efecto;

En consecuencia, señor Arbitro Único, en el presente caso, el Consorcio Huacarmayo cumplió con sus obligaciones contractuales y que la resolución unilateral fue injustificada, sin considerar los procedimientos legales cumplidos por el contratista, constituye un abuso de derecho, más aún tomado en cuenta que la Municipalidad debía actuar respetando las normas de contratación pública y los términos del contrato, lo cual no ocurrió. Toda vez que, las partes están obligadas a actuar de manera leal y transparente. Por lo que, corresponde restituir las condiciones previas, formalizando la recepción y conformidad del servicio ejecutado, en cumplimiento de los principios contractuales y normativos. Solicitamos se declare fundada la pretensión accesorio de la primera pretensión principal.

Posición de la DEMANDADA

- 6.33 La Arbitro Único deja constancia que, no obstante haber contestado la demanda, la MUNICIPALIDAD no ha formulado ningún argumento concreto sobre la presente pretensión.

Posición del ARBITRO ÚNICO

- 6.34 Previamente, debemos indicar que, tal como señalamos en el fundamento 6.31 del presente laudo, el Tribunal Arbitral ha determinado que las causales invocadas por la MUNICIPALIDAD para resolver el contrato, son infundadas o insuficientes, lo que implica que la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM y Carta Notarial N° 008-2024-MDH-GM, devienen en actos nulos e inválidos, ya que han sido emitidas sin haberse respetado el procedimiento establecido para su procedencia.

6.35 Conforme a ello, habiéndose determinado la invalidez de la resolución del contrato efectuado por la MUNICIPALIDAD, corresponde enervar nuevamente los efectos jurídicos del Contrato N° 004-2023-MDH/GM y, consecuentemente, por restituidas los derechos y obligaciones de las PARTES dentro del proceso de ejecución contractual.

6.36 Ahora, respecto a la segunda parte de la pretensión referida a la formalización de la recepción del servicio, debemos de recordar que, tal como señala MORÓN URBINA y AGUILERA B.¹³, la recepción de la prestación es el acto físico por la cual el proveedor entrega a la entidad el bien, servicio u obra a su cargo, para que sea verificada por la entidad a fin de que le otorgue conformidad a la misma. Así, en este acto, la entidad contratante verifica la oportunidad en que se produce la entrega, la cantidad y la calidad de la prestación debida. Si advierte defectos no hay lugar a recepción. Con la entrega y recepción de la prestación se produce el traslado del riesgo de la pérdida del bien hacia la administración.

6.37 Entonces, la recepción implica la entrega formal del servicio hacia la entidad, verificándose previamente que ésta cumpla las condiciones técnicas y calidad ofertadas.

6.38 En ese sentido, habiéndose restituido los derechos y obligaciones de las PARTES dentro del proceso de ejecución contractual, corresponde proseguir con el procedimiento de recepción del servicio tal como dispone el art. 168 del RLCE, motivos por los cuales corresponde amparar en su totalidad la presente pretensión.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que, el Árbitro Único, condene a una o a las dos partes el pago de la totalidad de costas y costos irrogados en el presente proceso arbitraje.

Posición del DEMANDANTE

6.39 El DEMANDANTE señala:

¹³ MORÓN URBINA, Juan Carlos y AGUILERA B., Zita. Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal- Colección Lo Esencial del Derecho N° 9. Fondo Editorial de la PUCP. 1° Edición. Lima-Perú. 2017. Pág. 155.

330
Trescientos treinta

"Que, el Árbitro Único, condene a la Municipalidad Distrital de Huácar, a pagar la totalidad de costas y costos irrogados en el presente proceso arbitraje."

Que, la DEMANDADA deberá correr con las costas y costos que se deriven de todo el proceso arbitral por haberlo generado negligentemente.

Posición de la DEMANDADA

6.40 Por su parte, la DEMANDADA señala:

1.2 Que, correspondiente a la segunda pretensión, en la que solicita a que se realice el pago total de las costas y costos irrogados en el presente proceso, éste pago se realizará siempre y cuando sea amparada la primera pretensión de su demanda, emitiéndose el laudo a favor de la empresa, amparando la primera pretensión, anteriormente señalada.

Posición del ARBITRO ÚNICO

6.41 Podríamos definir a los costos del arbitraje como aquellos gastos que atender a raíz del inicio de un proceso arbitral, tales como los honorarios del abogado, el traslado de los medios de prueba al proceso, los gastos administrativos y en especial, los honorarios de los árbitros, siendo que, en su escrito de Demanda Arbitral, el CONSORCIO solicita que la MUNICIPALIDAD asuma los costos generados por el presente arbitraje.

6.42 Considerando que, en el convenio arbitral celebrado por las PARTES, **no existe pacto expreso sobre la forma de imputar los costos y gastos del arbitraje**, corresponde aplicar las reglas establecidas por las partes en el ACTA DE INSTALACIÓN, el REGLAMENTO y supletoriamente lo dispuesto en la LEY DE ARBITRAJE, en ese orden de prelación.

6.43 Los numerales 52 y 53 del ACTA DE INSTALACIÓN establecen:

"... 52. En caso de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que el Árbitro se pronuncie al momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.

53. Sin perjuicio que el Árbitro pueda establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje..." (Resaltado Agregado)

6.44 Por su parte EL REGLAMENTO en su artículo 103 establece lo siguiente:

329-
Trescientos
veintinueve

"... Distribución de los costos arbitrales

Artículo 103°.-

Los árbitros se pronunciarán en el laudo que pone fin a la controversia sobre la imputación de los costos del arbitraje, atendiendo a lo establecido en el convenio arbitral. De no existir acuerdo al respecto, los costos serán de cargo de la parte que haya sido vencida en el arbitraje.

Sin perjuicio de ello, los árbitros podrán disponer la distribución de los costos del arbitraje entre las partes, si lo considera atendible de acuerdo a lo ocurrido en el arbitraje..." (Resaltado Agregado)

6.45 Finalmente, el numeral 1 del artículo 73° de la LEY DE ARBITRAJE señala:

"... Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso..." (Resaltado Agregado)

6.46 Conforme a ello, la regla general dicta que la asunción de costos y gastos arbitrales lo efectúa la parte vencida, debido que por su accionar indebido o irregular se tiene por consecuencia el proceso arbitral, dicho de otro modo, el reparto de esos gastos se hará teniendo en cuenta -en primer orden- el acuerdo que las partes hayan asumido, pero si no se pactó nada se recurrirá a la vieja fórmula: "el que pierde paga" (Teoría del Vencimiento). Dentro de nuestra legislación arbitral si bien opera la fórmula del vencimiento, ella no es absoluta pues se permite al juez cierta discrecionalidad al graduar el monto de los gastos procesales en atención a las incidencias del proceso, esto significa que los árbitros podían modificar el monto de los gastos aún sobre la voluntad de las PARTES o esta discrecionalidad sólo operaría cuando no hay pacto expreso y rige el principio del vencimiento.

6.47 Para nuestro caso debemos tener en cuenta que el ACTA DE INSTALACIÓN ha otorgado la potestad al Árbitro Único de determinar en el Laudo Arbitral el sentido de la condena respecto de los costos y gastos arbitrales, así como los conceptos que se deben considerar como tales. Siendo ello así, en el presente proceso arbitral, se han presentado tres pretensiones principales, incluyendo la presente, evidenciándose que ambas PARTES han formulado sus respectivos medios de defensa y dejándose constancia que el CONTRATISTA es quien ha asumido el pago de la totalidad de los gastos arbitrales, ante la renuencia de la MUNICIPALIDAD, evidenciándose que el CONSORCIO ha tenido que recurrir al arbitraje para enervar sus derechos ante el

actuar inmotivado de la MUNICIPALIDAD; desprendiéndose además que durante el transcurso del proceso si bien la MUNICIPALIDAD se apersona a la instancia y contesta la demanda, de manera injustificada ha omitido efectuar el pago de los costos arbitrales a los cuales se encontraba obligado, confirmándose de esta forma la conducta renuente de dicha parte procesal.

6.48 Ahora bien, para imputar o distribuir los costos del arbitraje, a falta de acuerdo de las Partes, la suscrita Arbitro Único determina que estos serán asumidas por ambas partes de forma equitativa, correspondiendo que la MUNICIPALIDAD reembolse a favor del CONTRATISTA la suma de S/ 7,7500.00 (Siete Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Soles).

6.49 Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar fundado en parte el presente punto controvertido.

7. PARTE RESOLUTIVA:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, la Arbitro Único, en Derecho, LAUDA:

✓ PRIMERO. - **DECLARAR FUNDADA** el primer punto controvertido, consecuentemente, se **DECLARA** la **NULIDAD** e **INEFICACIA** de la Resolución de Gerencia Municipal N° 267-2024-MDH/GM de fecha 14 de agosto de 2024 y de la Carta Notarial N° 008-2024-MDH-GM, con las cuales la Municipalidad Distrital de Huácar Resuelve en forma total el Contrato N° 004-2023-MDH/GM.

SEGUNDO. - **DECLARAR FUNDADA** el segundo punto controvertido, consecuentemente, se **DISPONE** el restablecimiento de los efectos jurídicos, derechos y obligaciones del Contrato N° 004-2023-MDH/GM suscrito para la ejecución del servicio "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO HUACARMAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"; **ORDENÁNDOSE** a la Municipalidad Distrital de Huácar que prosiga con el tramite de la Recepción del Servicio, conforme se encuentra dispuesto en el art. 168 del RLCE.

TERCERO. - **DECLARAR FUNDADA EN PARTE** el tercer punto controvertido, en consecuencia, **SE DISPONE** que ambas partes asuman los costos arbitrales de forma equitativa, **ORDENÁNDOSE** a la Municipalidad Distrital de Huácar que realice el pago y/o reembolso a favor del Consorcio Huacarmayo de la suma de S/ 7,7500.00 (Siete Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Soles).

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talim
SECRETARÍA ARBITRAL

Disponer que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el presente Laudo Arbitral, la Secretaría Arbitral cumpla con notificarlo a las partes en la forma establecida por éstas, sin perjuicio de registrarlo en el Portal del SEACE de acuerdo a la ley de la materia. -

Firmado:


Abog. Heidi Ivonne Santos Torres de Kulesza

Arbitro Único

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO ÚNICO


Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur

Secretaria Arbitral